2024년 특허·상표
판례연구논문 공모전
우수논문집

Intellectual Property
Trial and Appeal Board

01

최우수상

박선하 / 양인수

신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변에 관한 연구

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결
제 목	신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변에 관한 연구
요 약	대상판결은 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것이므로, 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 없다고 판시한 사례임 다만, 대상판결에도 불구하고, 디자인 보호법 상 신규성 상실의 예외 규정의 취지가 무엇인지 그리고 자유실시디자인의 운용은 어떻게 해야 하는지는 명확하지 아니하여 이에 대한 연구가 필요한 상황임 본 판례 연구에서는 신규성 상실의 예외 규정의 주요 쟁점에 대하여 일본, 미국, 유럽 등 주요국과의 비교 연구를 통하여 개선점을 제시하였고, 자유실시디자인의 항변에 대하여는 일본, 중국 등의 주요국의 운용과 비교하여 바람직한 운용 방향을 제시하여 보았으며, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계에 대해서 검토하였음 우선 신규성 상실의 예외규정과 관련하여, 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건의 완화 방향은 기본적으로 타당함을 검토하였고 나아가 특허법 상의 공지예외주장제도와는 기본적인 차이가 있음을 지적하였음. 또한 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 규정의 완화에 따라서 실체적 요건이 중요해질 것이라고 파악하였음. 구체적으로 실체적 요건으로서, 출원디자인과 공지디자인의 동일·유사 정도(즉, 공지디자인의 범위), 제3자에 의해 디자인의 공지된 경우의 취급 등 향후 예상되는 다양한 쟁점에 대하여 일본, 미국, 유럽 등의 주요국의 운용현황과 비교분석함으로써 우리나라의 운영상의 개선점을 제시하였음. 나아가, 관련디자인 제도와의 관계에서 신규성 상실의 예외 규정의 운용에 대해서 법 규정을 명확히 해야 하는 점과 운용상의 개선점을 제시하였음. 마지막으로, 자유실시디자인의 항변의 운용에 있어서, 창작비용이성 판단의 확대 적용의 제한, 디자인 유사여부 판단기준의 정합성 제고 및 등록디자인의 고려 등 운용상의 개선점을 제시하였고. 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변과의 관계에 대해서도 검토하였음.
필 요 성	대상판결은 자유실시디자인의 항변의 기초가 되는 공지디자인이 될 수 없다고 하여, 일견 특허권자에게 유리한 입장의 판결을 한 것으로 보임.

	그러나 대상판결은 신규성 상실의 예외 규정과 관련한 절차적 요건이 삭제되기 이전의 구 디자인보호법 제36조 [법률 제11848호 2014. 7. 1. 시행]에 따른 것으로, 절차적 요건이 삭제된 현행법의 운용에서도 그대로 적용될 수 있는지 등에 대해서는 검토의 여지를 남김 따라서 특허법과의 차이점을 염두 해 둔 국내 디자인보호법 특수성을 감안한 운용방향을 설정하고, 제3자와의 형평성을 고려하여 현행의 삭제된 절차적 요건을 보완하기 위한 실체적 요건의 주요 쟁점에 대한 검토가 필요한 시기라고 할 것임. 또한 자유실시디자인의 항변이 권리범위확인심판 등에서 많이 활용되고 있는바, 논리적 일관성을 담보하기 위해 디자인의 동일·유사 판단방법은 어떻게 운용되어야 하는지, 현재 자유실시디자인의 항변에서 창작비용이성까지 판단하는 것이 타당한 것인지에 대하여 검토가 필요한 상황임.
독 창 성	대상판결에 대한 단순한 분석을 넘어서, 대상판결로 인해 향후 발생할 문제점 및 대상판결이 다루지 못했지만 향후 이슈가 될 쟁점들을 총 망라하여 체계적으로 정리하였음. 대상판결에 대한 인한 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시 항변을 특허법 관점에서 풀어낸 논문들은 일부 있었으나, 디자인보호법만의 특수성을 감안한 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변에 대한 체계적인 검토는 본 논문만의 특징이라고 할 수 있음 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변과 관련하여, 일본, 중국, 미국, 유럽 등의 주요국의 운용 및 법리로부터, 국내의 개선점을 제시하였으며, 최근 5년간의 특허법원 판결 분석을 통해서 권리범위확인심판에서 자유실시디자인 항변의 실제 운용 현황을 분석한 점 등은, 다른 연구에서 찾아 볼 수 없는 본 연구만의 독창적인 내용들임.
파급효과	**(심사제도 개선·심판기준 정립)** 신규성 상실의 예외 규정의 개선점을 제시함으로써 향후 디자인보호법 개정시 활용될 수 있을 것이고, 자유실시디자인의 항변에 관한 개선점을 제시함으로써, 권리범위확인심판을 담당하는 특허심판원의 심판기준 정립에도 크게 기여할 것으로 생각됨. **(산업계)** 신규성 상실의 예외 규정을 주장하는 출원인들에게 유리한 개선안을 제시하였고, 특히 관련디자인과 신규성 상실의 예외 규정과의 관계를 명확하게 할 것을 제시함으로써, 법률의 예측 가능성을 높일 것으로 기대됨. **(변리업계)** 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인에 관한 주요 쟁점들을 분석·제시하였는바, 변리업계에도 도움이 될 것으로 생각됨.

최우수상

신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변에 관한 연구

대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결

목 차 / Contents

1. 서론 ····· 5
2. 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변 ····· 7
가. 신규성 상실의 예외 규정
(1) 취지 및 효과
(2) 법 개정 연혁
(3) 특허법 공지예외주장제도와의 비교
나. 자유실시디자인의 항변
(1) 자유실시디자인의 항변의 의의
(2) 국내 판례의 전개
3. 대상판결의 개요 ····· 19
가. 등록디자인과 확인대상디자인의 대비
나. 소송의 경과
다. 대상판결의 판시
4. 신규성 상실의 예외 규정의 주요쟁점에 대한 검토 ····· 24
가. 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건
(1) 문제의 소재
(2) 주요국의 운용
(3) 개선점
나. 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건
(1) 문제의 소재
(2) 주요국의 운용
(3) 개선점
다. 관련디자인 제도와의 관계에서 신규성 상실의 예외 규정
(1) 문제의 소재
(2) 일본의 운용
(3) 개선점
5. 자유실시디자인의 항변에 대한 검토 ··· 47
가. 문제의 소재
나. 주요국의 법리
(1) 일본
(2) 중국
다. 개선점
(1) 창작비용이성 판단의 확대 적용의 제한
(2) 디자인 유사여부 판단기준의 정합성 제고 및 등록디자인의 고려
6. 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계에 대한 검토 ····· 62
가. 대상판결이 제시한 관계 및 이에 대한 평가
(1) 대상판결이 제시한 관계
(2) 평가
나. 개선점
(1) 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건 완화에 따른 관계의 재정립
(2) 공지디자인 예외 규정으로의 법 개정
7. 결론 ····· 68

1 서 론

디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변이 인정될 수 있는지에 관해서는 그 견해가 나뉘어 왔다.

자유실시디자인의 항변을 부정하는 입장에서는, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인에 대해 자유실시디자인으로 인정하게 되면, 자기 공지 등 신규성 상실의 예외 사유가 있는 등록디자인의 경우 그 등록이 무효로 되지는 않지만 이를 실시하는 제3자에 대하여 실제로 권리행사를 할 수 없는 형해화된 권리로 전락하게 된다는 문제점을 지적한다.[1] 신규성 상실의 예외 규정의 존재 의의, 출원 이후 실시한 자를 보호할 법적 필요성이 있는지 등을 고려할 때, 신규성 상실의 예외 규정을 적용받아 등록된 디자인권의 효력을 우선하여 그 권리범위를 인정하는 것이 타당하다는 입장인 것이다.[2] 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 2016가합502475, 575398(병합) 판결 등에서도 신규성 상실의 예외가 인정되어 등록된 공지디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당되지 않는 것으로 판단하여 이를 근거로 한 자유실시디자인의 항변은 인정할 수 없음을 판시한바 있다.

반면, 자유실시디자인의 항변을 긍정하는 입장에서는, 자유실시디자인 법리의 도입 취지에 비추어 창작 비용이성 판단의 근거가 되는 선행디자인과 자유실시디자인의 기초가 되는 선행디자인의 범위를 동일하게 보는 것이 논리적이라는 점을 그 이유로 든다.[3] 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결, 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1028 판결(대상판결의 원심)에서는 신규성 상실의 예외는 등록요건 판단에서 적용되는 것이고, 신규성 상실의 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변까지 불가능하게 한다면 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 도입된 신규성 상실의 예외 규

1) 김기수, "자유실시디자인 판단 시 신규성 상실의 예외 규정 적용 가능성", 『Law&Technology』, 제16권 제3호(2020), 1110면.

2) 신기현, "공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌 —서울중앙지방법원 2018. 12.13. 선고 2016가합502475 판결을 중심으로—", 『지식재산연구』, 제14권 제4호(2019), 56면.

3) 김기수, 앞의 글(주 1), 1110면.

정의 도입 취지에도 반하게 된다는 등의 이유를 들어 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변을 인정하였다.

이처럼 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변과의 관계에 관한 견해가 나뉘고 법원의 판결에서도 통일된 판단이 부재하다는 점에서, 판단기준 정립의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔고,[4] 신규성 상실의 예외 규정의 의미와 효력 등을 명확하게 정립하지 않으면 그 동안 특허청에서 디자인보호법상 신규성 상실의 예외의 적용범위를 확대해 왔던 여러 입법적인 노력들이 효과가 없게 될 수도 있다는 우려도 제기된다.[5]

최근 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결(이하 '대상판결')에서는 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판시함으로써, 신규성 상실의 예외 주장의 근거가 되는 디자인으로는 자유실시디자인의 항변이 불가능하다는 법리를 명확히 하였다.[6]

이 글은 대상판결을 분석하고 나아가 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 운용상의 개선방안을 제시하고자 한다. 우선, 신규성 상실의 예외 규정과 관련하여서는, 디자인보호법의 법 목적 및 국내의 상황에 부합하는 절차적 요건 및 실체적 요건의 운영방향, 관련디자인 제도와의 관계 규정에 대해서 검토해 본다. 다음으로, 자유실시디자인 항변과 관련하여서는, 국내에서의 실제 활용 현황

4) 가령, 특허법원 2019. 11. 22. 선고 2019허4703 판결에서 피고들은 이 사건 등록디자인에 관한 선행디자인이 자기 의사에 반하여 공지되었고, 이에 대해 신규성 상실의 예외에 해당하여 해당 선행디자인을 근거로 하는 자유실시디자인의 항변은 인정되어서는 안 된다는 취지의 주장을 하였으나, 재판부는 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받기 위한 증명서류의 제출 등 절차적 요건을 구비하지 아니하여 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받을 수 없다는 판단 하에, 해당 선행디자인을 근거로 하는 자유실시디자인의 항변을 인정하였다. 이 사건의 경우 절차적 요건을 구비하지 못 하였기 때문에 해당 선행디자인을 근거로 하는 자유실시디자인의 항변을 인정하는 것은 당연하다고 볼 수 있을 것이나, 절차적 요건을 구비하였을 경우 자유실시디자인의 항변을 인정하였을지는 알 수 없다.

5) 정태호, "디자인보호법상 창작자 보호 관점에서의 신규성 상실의 예외에 관한 고찰", 『산업재산권』, 제71호(2022), 93면.

6) 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결의 상고심인 대법원 2023.2.23.선고 2021후10473 판결에서도 대상판결과 동일한 취지의 판시를 하였다.

을 조사하고 주요국의 운용 현황을 분석함으로써, 국내 운용에 있어서의 개선점을 마련해보고자 한다. 마지막으로, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인 항변과의 관계에 대해서 대상판결에서 제시한 논거에 관하여 검토하여 봄으로써, 향후의 개선점을 제시해 보고자 한다.

2 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변

가 신규성 상실의 예외 규정

(1) 취지 및 효과

디자인보호법 제36조 제1항에서는 "디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다."라고 하여 신규성 상실의 예외를 규정하고 있다. 신규성 상실의 예외 규정은 국제조약상 강제적인 것은 아니나, 대다수의 주요 국가들이 법률상 채택하고 있는데, 세부적인 적용요건은 국가별로 차이가 있다.[7][8]

신규성 상실의 예외 규정의 취지와 관련하여, 대법원 판례(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)에서는 "디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자

7) 정태호, 앞의 글(주 5), 95면.

8) 일반적으로 grace period라고 하는데, grace period는 특정 조건 하에서 디자인·특허출원까지 행한 디자인·발명의 공개에 의해 그 본인의 디자인·발명의 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하는 일정한 유예기간을 의미한다. 즉, grace period 기간 내 디자인·특허출원을 하면, 해당 공개에 의해 디자인·발명이 공개되었음을 이유로 신규성 또는 용이창작·진보성으로 거절되지 않는다.

인보호법 제33조). 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정(디자인보호법 제36조)을 두었다."고 그 취지를 판시하고 있다.

창작자의 권리보호 및 창작의욕의 고취라는 입법취지는 해당 법률의 개정에 관한 국회 소관위의 검토보고서에서도 잘 나타나 있는데, 특허법에서의 공지예외 주장 제도(특허법 제30조: 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)와는 달리 신규성 상실의 적용의 범위를 확대한 것은 디자인이 특허보다는 '진정한 권리자에 대한 창작 장려의 목적'이 더 강하므로 공개된 디자인은 이에 대한 권리화를 법률로 허락할 필요성이 더 크다고 언급하고 있다.[9] 이러한 개정법률의 입법취지를 볼 때 신규성 상실의 예외는 단순히 공지디자인을 공지되지 않았던 것으로 보아주는 것뿐만 아니라, 이에 따라 진정한 창작자에게 독점적인 지위에 관한 권리화를 보장해 주려는 취지의 방법으로서 그 의미를 둘 수 있을 것이다.[10]

신규성 상실의 예외가 인정되면 그 공지디자인은 자기가 출원한 디자인에 대하여 디자인보호법 제33조 제1항(신규성) 및 제2항(창작의 비용이성)에 해당하는지 여부를 심사할 때 공지디자인으로 보지 않는 것으로, 출원일 자체가 소급되는 것은 아니다.[11] 즉, 디자인등록을 받을 수 있는 자가 공개한 것에 기초한

9) 통상산업위원회전문위원, "의장법중개정법률안 검토보고서", 통상산업위원회, 1997, 4면[정태호, 앞의 글(주 5), 104면 재인용].

10) 정태호, 앞의 글(주 5), 97면.

11) 峯 唯夫, 『33のテーマで読み解く意匠法』, 勁草書房, 2023, 129-130면[가령, 출원 디자인 그 자체의 공지와 관련된 것이 아닌 관련한 물품의 공지를 증명하는 서류를 제출할 수도 있을 것이나, 해당 증명서류에 관하여 신규성 상실의 예외 주장은 인정되지 않으며, 인정된다 하더라도 해당 공지 사실에 관해서만 신규성, 창작비용이성 등의 판단자료로 삼지 않는다는 것임을 의미하므로 해당 증명자료를 인정할 실익은 없다 할 것이다].

타인의 디자인 공개의 경우에도 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있으나, 신규성을 상실한 시점부터 출원 시까지의 기간 동안에 타인이 동일 디자인을 공개하거나 출원을 하는 경우에는 신규성 상실의 예외의 적용을 받을 수 없다.[12] 가령, 신규성 상실의 예외 규정의 적용의 대상이 되는 공개 A를 한 후에 디자인 출원 A를 한 경우, 그 출원일과 동일한 날에 제3자인 다른 출원인이 유사한 디자인 A'에 관해 디자인 출원 A'을 하였다면, 제3자의 디자인 출원 A'은 공개된 A에 의해 신규성을 상실했다는 이유로 디자인 등록을 받을 수 없으며, 디자인 출원 A의 경우도 동일자 선출원 규정에 따른 협의를 할 수 없는 경우에 해당하여 디자인 등록을 받을 수 없게 될 것이다.[13] 이처럼 본 규정은 신규성에 관한 예외 규정으로 출원일이 소급되는 것이 아니므로, 본 규정의 적용을 충족하는 공개를 한 경우에도 가능하면 빨리 출원을 하는 것이 바람직하다.

(2) 법 개정 연혁

신규성 상실의 예외 규정은 디자인 창작자를 보호하고 산업 발전을 도모한다는 취지에서 수차례 개정이 이루어져 왔다.[14]

1997. 8. 22. 개정 의장법(법률 제5334호, 시행 1998. 3. 1.)에서는 창작자의 권리확보의 기회를 확대시킨다는 취지하에 공개 사유에 관계없이 신규성 상실의 예외를 인정하였다.[15]

2001. 2. 3. 개정 의장법(법률 제6413호, 시행 2001. 7. 1.)에서는 해당 규정의 적용을 받을 수 있는 대상을 분명하게 하기 위해 해당 규정의 적용을 받을 수 있는 주체로서 '그 자가 의장등록출원을 하는 때는'으로 개정하였는데,[16] 법률상 개정 취지를 고려하면, 신규성 상실의 예외의 근거가 되는 공지디자인은

12) 中山信弘 編,『新·注解 特許法〔第2版〕』, 弘文堂, 2017, 351-352면[酒井仁郎·川崎隆二 집필부분].

13) 中山信弘 編, 앞의 글(주 12)、351-352면.

14) 법률 개정의 구체적 연혁 및 내용에 관해서는 윤태식,『디자인보호법 - 디자인 소송 실무와 이론 -』, 진원사, 2016년, 215-216면; 정태호, 앞의 글(주 5), 102-114면 참조.

15) 개정 전에는 학술단체, 박람회 등에서 공개된 경우에 한하여 인정하였다.

16) 정태호, 앞의 글(주 5), 104-105면.
개정 전에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 타인의 독립적인 창작과 공지행위에 기초해서 공지된 경우에도 그 때부터 6월 이내에 출원을 하면 해당 규정이 적용되는 것으로 해석될 여지가 있었다.

디자인등록을 받을 수 있는 권리에 토대를 두어야 한다는 것을 의미하며, 해당 공지디자인은 디자인권이라는 독점적인 지위의 측면에서 그 디자인권자가 누구에게나 해당 공지디자인의 독점권을 주장할 수 있고, 해당 공지디자인이 더 이상 자유영역의 범주에 해당되지 않는다는 것임을 확인할 수 있는 것이라 평가된다.[17]

2004. 12. 31. 개정 디자인보호법(법률 제7289호, 시행 2005. 7. 1.)에서는 공지디자인의 경우에도 제5조 제2항의 창작비용이성의 판단의 기초가 되는 것으로 개정되었는데, 창작비용이성을 판단할 때에도 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인이 그 근거가 되지 않도록 개정되었다.[18] 개정 취지에 대한 해석에 비추어 보면, 제3자의 실시디자인에 대해서도 해당 공지디자인에 근거한 독점적 지위를 가지는 것이라고 볼 수 있으므로, 이러한 공지디자인에 근거하여 자유실시영역의 디자인임을 판단하는 것은 타당하지 않은 것이라는 의견도 제시되었다.[19]

2007. 1. 3. 개정 디자인보호법(법률 제8187호, 시행 2007. 1. 3.)에서는 '그 디자인 또는 이와 유사한 디자인은'을 '그 디자인'으로 수정하면서 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대하여 특별한 내용을 추가하지 않아 양 디자인이 동일 또는 유사한지 여부에 상관없이 출원디자인이 소정의 요건만 충족하면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있게 되었다.

2013. 5. 28. 전부개정 디자인보호법(법률 제11848호, 시행 2014. 7. 1.)에서는 디자인등록을 받을 수 있는 자의 출원상의 편의 증진을 위해 출원 시에만 할 수 있도록 하던 것을 거절이유통지를 받거나 디자인일부심사등록 이의신청, 등록무효심판이 제기된 경우 이에 대한 의견서 또는 답변서를 제출할 때에도

17) 정태호, 앞의 글(주 5), 105면.

18) 정태호, 앞의 글(주 5), 106면.
개정 전에는 디자인보호법 제8조는 '①의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의장이 제5조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우 그 날부터 6월 이내에 그 자가 의장등록출원을 하는 때에는 그 의장 또는 이와 유사한 의장은 동항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.'라고 되어 있었으나, 개정 후에는 '동조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서'와 같이 제2항의 창작비용이성 규정이 추가되었다.

19) 정태호, 앞의 글(주 5), 107면.

할 수 있도록 규정하였고, 자기의 의사에 반한 공지인지 여부의 구분을 삭제하였다. 신규성 상실의 예외 주장에 대한 기회를 대폭 확대한다는 측면에서 타당한 입법이라 평가된다.[20] 다만, 개정 전 디자인보호법 제8조 제2항 단서에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우 별도의 서면이나 증명서류를 제출할 필요 없이 신규성 상실의 예외 규정이 적용되었던 것과 달리,[21] 전부 개정된 제36조 제2항에 의해 자기 의사에 반한 공지의 경우에도 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받으려면 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하도록 되었다는 점에서, 그 개정의 취지와는 다르게 자기 의사에 반한 공지에 대해서는 구제 가능한 범위가 오히려 제한되게 되었다.[22]

2017. 3. 21. 개정 디자인보호법(법률 제14656호, 시행 2017. 9. 22.)에서는 신규성 상실 후 디자인등록출원을 할 수 있는 기간을 '6개월 이내'에서 '12개월 이내'로 연장하고, '거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때'를 '디자인등록여부결정의 통지서가 발송되기 전까지(디자인등록여부결정 전까지)'로 변경하여, 출원인의 편의를 제고하였다.

2023. 6. 20. 법률 제19494호(2023. 12. 21. 시행)로 일부 개정된 디자인보호법에서는 제2항의 절차적 규정을 삭제하였다. 즉, 신규성이 상실된 날로부터 12개월 이내라는 시기적 요건에만 부합하면 신규성 상실의 예외의 주장이 가능하게 되었다. 개정 전에는 무효심판의 답변시의 제출 시에 추가적으로 인정될 수 있는 것으로 되어 있었기 때문, 디자인권 침해소송이나 권리범위확인심판 등에서는 신규성 상실의 예외 주장이 인정되지 않거나, 무효심판이 없는 경우 주장을 할 수 없는 등의 문제가 지적되어 왔으며, 자기 의사에 반한 공지의 경

20) 정태호, 앞의 글(주 5), 111면.

21) 디자인보호법 제8조 제2항 '다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.'라고 규정되어 있어, 증명서류를 제출할 필요가 없었다.

22) 가령, 특허법원 2019. 11. 22. 선고 2019허4703 판결에서는 '등록디자인 출원 이전에 적용되던 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것) 제8조 제2항 단서에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우 별도의 서면이나 증명서류를 제출할 필요 없이 신규성 상실의 예외 규정이 적용되었던 것과 달리, 등록디자인 출원 당시 적용되던 디자인보호법(법률 제11848호로 전부개정된 후의 것)에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우에도 신규성 상실 예외 규정을 적용받으려면 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 하는바, 등록디자인이 자기 의사에 반한 공지에 해당하는지 여부를 따져볼 실익이 없다.'고 판시하였다.

우에도 제36조 제2항 각호에서 정한 시기에 증명서류를 제출해야 하는 번거로움이 있었는데, 이번 개정에 의해 이러한 증명서류의 제출이 필요 없게 되었다.[23]

신규성 상실의 예외 규정의 적용과 관련해서 단순히 신규성이 상실되지 않았다고 보는 것을 넘어서 출원인의 권리확보의 유리함을 계속 강조하고 있는바, 그 입법 방향은 창작자 자신의 공지디자인에 대한 디자인권 확보라는 취지를 더욱 강화하는 방향으로 흘러왔고, 이러한 의미에서 '창작자의 독점실시디자인 영역'으로 인정하기 위해 지원하는 제도라 평가되기도 한다.[24]

(3) 특허법 공지예외주장제도[25]와의 비교

디자인보호법상 신규성 상실의 예외 규정은, 2013년 전부개정(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정된 것, 2014. 7. 1. 시행) 및 2017년 개정(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정된 것, 2017. 9. 22. 시행)의 2차례의 개정에 의해 특허법과는 상이한 내용으로 변경되었다.[26] 2차례 개정에 있어 공통된 개정취지는 디자인권자의 권리 보호를 확대하는 것으로서, 비교법적으로도 선진적인 입법으로 평가될 수 있다.[27] 발명 등은 외관이 사람들의 눈에 띄더라도 금

---

23) 이러한 개정의 배경으로, 무효심판청구의 답변서 제출 단계에서 디자인등록 이후 신규성 상실의 예외에 관한 후발적인 주장이 있을 경우에 제3자의 이익을 해할 우려가 있으므로, 자유실시디자인을 통해 신규성 상실의 예외가 인정된 디자인권의 효력을 제한한다는 특허법원에서의 2개의 판결들이 영향을 미쳤다는 견해도 제시된다[정태호, "자유실시디자인과의 관계에 따른 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 개정 규정 관련 입법론의 비판적 검토- 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결 및 2022후10012 판결의 분석을 중심으로 -",『정보법학』, 제28권 제1호(2024), 7면].

24) 정태호, 앞의 글(주 5), 113면.

25) 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우).

26) 참고로, 일본의 경우도 현행 의장법 제정 당초부터 특허법이나 실용신안법과 비교하여 의장등록을 받을 권리를 가진 자의 행위에 기인한 경우 상대적으로 광범위한 예외가 인정되어 왔다. 즉, 발명이나 고안은 한 번 공개되면 사회의 기술수준의 일부가 되어 그 위에 기술활동이 축적되어 가는 것이기 때문에, 그러한 공개된 발명이나 고안에 나중에 특허나 실용신안등록을 부여하는 것은 기술활동을 저해하는 것으로 여겨져 신규성 상실의 예외를 인정하는 범위를 한정해 왔었다. 반면, 의장의 경우에는 그러한 병폐를 상정할 수 없기 때문 사회 실정에 맞게 신규성 상실의 예외의 범위를 넓게 인정하였다.[峯 唯夫, 앞의 글(주 11), 129면; 佐々木眞人, "新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和の必要性及び今後の期待",『パテント』, Vol. 76 No. 5(2023), 80면].

27) 신상민, "디자인보호법상 자기공지에 의한 신규성 상실의 예외의 법적 쟁점",『법학연구』, 제20집 제3호(2017), 3면.

방 공지가 되는 것이라 볼 수 없으나, 디자인은 사람의 시각에 호소하는 외관이기 때문에 한 번 사람들의 눈에 띄게 되면 쉽게 모방될 가능성이 있으며, 이 때문에 권리자의 의사에 반하여 출원 전에 공지가 되기 쉽다.[28] 또한 실제 제품으로 판매할 디자인을 결정할 때, 전시나 견본의 배포 등을 통해 수요를 타진해 보는 것이 일반적이며, 최근에는 클라우드 펀딩에 의해 자금을 조달할 때 디자인을 공표하는 등 디자인을 공개하는 기회가 늘고 있다.[29] 발명은 공개되면 사회의 기술 수준의 일부가 되고, 그 위에 기술활동이 축적되어 진보되어 가는 것으로, 공개된 기술에 대해 특허를 부여하는 것은 기술활동을 저해하는 것이 되어 널리 예외를 인정하는 것이 법의 목적에도 부합하지 않으나, 디자인의 경우 그러한 병폐가 없기 때문에 특허와 비교하여 상대적으로 예외를 널리 인정할 수 있다고 판단되어 왔다.[30]

특허법과 디자인보호법의 경우 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다는 점에서 그 법의 목적은 공통되나 공개에 관해서는 서로 다른 입장을 취하고 있기 때문에,[31] 이러한 점을 고려하면 신규성 상실의 예외 주장의 인정 범위에 관해서도 양자의 차이를 인정하는데 큰 무리는 없을 것이라 생각된다. 특허법은 법 목적에 산업발달을 위한 구체적 방책으로서 '발명을 보호·장려하고 그 이용을 장려함으로써 기술 발전을 촉진'이라고 규정되어 있는데, 우수한 발명의 창작과 사회에의 공개가 활성화됨에 따라, 새로운 이노베이션이 발생될 것을 기대할 수 있고, 신규한 생산수단, 신제품, 신규 서비스 등이 실현되고, 이를 통해 시장 자체의 확대, 신규한 시장의 창생이라는 현상이 발생하는 파급적 효과를 기대할 수 있는 것이다.[32] 반면,

28) 高田 忠,『意匠』, 有斐閣, 1982, 208면; 峯 唯夫、앞의 글(주 11), 129면.

29) 峯 唯夫、앞의 글(주 11), 129면.

30) 鈴木康平, "意匠法における新規性喪失の例外規定の検討",『日本知財学会誌』, Vol. 19 No. 1 (2022), 75면.

31) 디자인보호법 제1조(목적)에는 '이 법은 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.'라고 되어 있고, 특허법 제1조(목적)에는 '이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.'라고 되어 있어, 그 목적을 달성하기 위한 구체적 내용은 다소 다르다는 것을 알 수 있다. 디자인보호법의 경우, 디자인권자의 보호를 위해 출원공개제도를 규정하고 있지 않으며, 일정 기간 비공개 상태로 둘 수 있도록 비밀디자인제도를 규정하고 있는 한편, 관련디자인제도를 통해 유사한 컨셉의 디자인을 보호하는 등, 상대적으로 창작자 보호에 그 초점이 맞추어져 있다고 볼 수 있다.

32) 中山信弘·小泉直樹 編集、『新·注解 特許法』、青林書院、2017、6면[平嶋滝太 집필부분].

디자인보호법은 그 법 목적에 '디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여'라고 규정되어 있는데, '디자인의 창작의 장려'라고 하는 것은 디자이너, 즉 창작자의 보호라고 볼 수 있을 것이며, 이는 산업 발달이라는 종국의 목적과 결부되는 것이다.[33] 즉, 디자인보호법은 디자인권의 설정이라는 방법으로 디자인의 보호 및 이용을 도모하고, 직접적으로는 디자인의 창작을 장려하여, 종국적으로는 산업 발달에 기여하는 것을 목적으로 하고 있고, 창작자의 보호에 중점을 두고 있는 것이다.[34]

실제 실무에서도 디자인의 경우가 특허의 경우보다 신규성 상실의 예외 제도에 대한 의존성이 높다. 일본에서의 신규성 상실의 예외 주장의 절차 완화에 앞서 발표된 보고서에 따르면, 2021년 신규성 결여(일본 의장법 3조 1항 각호)를 이유로 거절이유가 통지된 2,621건(국제의장등록출원에 대한 거절이유 제외) 중, 약 16.7%인 437건이 자기의 1년 이내의 공개 디자인(국내외의 공보 제외)에 의해 거절이유가 통지되고, 나아가 그 중의 약 36.2%에 해당하는 158건이 출원 시에 예외적용 서면 및 예외적용 증명서를 제출했음에도 불구하고, 증명이 충분하지 않았던 점이 보고되었다.[35] 아울러, 해당 보고서에 따르며, 2020년 특허의 경우 전체 출원 중 약 1.3%가 신규성 상실의 예외 주장을 하였으나, 의장의 경우 전체 출원 중 약 8.2%가 신규성 상실의 예외 주장을 하였으며, 이러한 신청 건수나 비율은 증가추세라고 한다.[36]

디자인보호법에서 신규성 상실의 예외를 널리 인정한 이유로서 디자인 창작의 특유한 성질 이외에도, 창작자에 대한 구제적인 성격을 들 수 있는데, 즉, 디자인제도에 대한 지식이 많지 않은 디자이너나 중소기업 등은 법의 부지에 의해 스스로 디자인을 공개하고, 신규성을 상실하는 경우가 적지 않아, 이러한 점에서 창작자의 구제가 가능한 것이다.[37] 특히 특허나 실용신안등록과 비교하여 개인 출원의 비율

특허에서의 '보호'와 '이용'은 이른바 자동차의 양쪽 바퀴와 같은 것으로 이해될 수 있는데, 특허법은 단순히 발명보호법이 아닌 동시에 발명이용법으로서도 이해할 필요가 있다고 한다.

33) 高田 忠, 앞의 글(주 28), 2면.

34) 高田 忠, 앞의 글(주 28), 2면.

35) 特許庁政策推進懇談会, "知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~", 特許庁, 2022, 13면.

36) 特許庁政策推進懇談会, 앞의 글(주 35), 12면.

이 상대적으로 높다는 점에서도, 창작자의 구제적인 성격은 특허제도에서의 공지 예외주장 규정과 비교하여 큰 의의를 가진다 할 수 있을 것이다.[38]

나 자유실시디자인의 항변

(1) 자유실시디자인의 항변의 의의

자유실시디자인의 항변이란, 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 등록디자인과 대비되는 실시디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지거나, 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하는 것을 의미한다. 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이라 이해할 수 있다.[39] 아울러, 디자인권은 출원시의 창작수준을 넘는 디자인에 대해 부여되어야 하기 때문에, 침해소송의 대상이 된 피고제품이 출원시의 공지디자인의 실시인 경우, 그 디자인권에 대해 공지디자인을 포함한다는 이유로 금지청구 등의 권리의 행사를 인정하는 것은 디자인보호법의 기본원칙에 반한다고 하는 생각에 근거한다.[40]

---

37) 鈴木康平, 앞의 글(주 30), 75면.

38) 鈴木康平, 앞의 글(주 30), 75면.

39) 특허에 관한 사건이기는 하나, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결에서는 "권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다"라고 판시한 바 있다.

40) 三村量一, "他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合", 『最高裁判所判例解説民事編』, 平成10年度 (上)(2001), 128면[다만, 이 글에서는 특허의 자유기술의 항변을 다루고 있으나, 그 취지는 디자인보호법과 동일하다 볼 수 있을 것이다.].

한편, 우리나라의 권리범위확인심판에서는 자유실시기술이나 자유실시디자인의 항변이 많이 행해지고 실제로 상당 부분 받아들여지고 있는데, 그 이유는 침해소송과는 달리 권리범위확인심판에서는 대법원 판례에 의해 특허권이나 디자인권 등에 대한 진보성이나 창작비용이성의 무효여부에 대한 판단이 불가능하기 때문에, 이에 대한 우회수단으로서 자유실시기술 또는 자유실시디자인의 항변이 상대적으로 더욱 많이 주장될 수밖에 없는 것이다.[41][42] 권리범위확인심판 등 무효심판 이외의 절차에서 등록디자인의 무효사유에 대하여 심리 판단할 수 없게 되자, 그 대상을 등록디자인의 효력이 미치는지 여부가 문제되는 확인대상디자인으로 바꾸어서, 사실상 등록디자인의 무효사유에 대하여 간접적으로 심리판단을 하기 위해 발전한 이론으로 평가되기도 한다.[43] 이처럼 자유실시디자인의 항변은 공지디자인에 근거한 신규성은 물론 창작비용이성까지 포함하는 점에서, 권리범위확인심판에서의 공지디자인의 항변과는 차이가 있다.[44]

아울러, 디자인권의 무효 여부를 증명하기보다, 본인이 실시하고 있는 제품에만 주목하여, 해당 디자인이 퍼블릭 도메인 영역에 있는 자유실시디자인에 해당하는 것임을 증명하는 것이 상대적으로 용이하다는 점에서도, 피고의 입장에서는 자유실시디자인의 항변을 주장하기 쉬울 것이다.[45]

---

41) 정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 『성균관법학』, 27권 3호(2015), 274-275면.

42) 특허발명의 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 되는데, 이러한 취지에서 디자인권의 권리범위확인심판에서도 창작의 용이성을 이유로 공지디자인의 항변을 주장할 수 없다.

43) 박정희, “권리범위확인심판에서 특허권 소진을 주장할 수 있는지 여부”, 『특허판례연구』, 3판(2017), 704면.

44) 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 되는데, 이러한 취지에서 디자인권의 권리범위확인심판에서도 창작 용이성을 이유로 공지디자인의 항변을 주장할 수 없다.

45) 牧野利秋 編, 『最新知的財産訴訟実務 含·知財高裁歴代所長座談会』, 青林書院, 2020, 55면.
참고로, 일본의 경우 최근 공지기술의 항변(자유기술의 항변)의 역할이 재조명되고 있다. 특허법 104

(2) 국내 판례의 전개

대법원 1994. 9. 27. 선고 93후1995 판결에서는 “(가)호의장은 이 사건 등록의장의 출원 전에 국내에서 공지된 인용의장과 유사하여 이 사건 등록의장의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였는바”라고 하여, 등록디자인과 대비되는 실시디자인이 공지디자인과 유사한 경우 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이후 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서는 “등록의장과 대비되는 의장이 등록의장의 의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 · 모양 · 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록의장과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다 할 것 인 바”라고 하여, 등록디자인과 대비되는 실시디자인이 주지의 형태 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 경우에도 등록의장과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.[46] 아울러, 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결에서도 “등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리 범위에 속하지 않는다고 보아야 한다”고 판시하여, 주지의 형태만이 아니라, 공지디자인 또는 이들의 결합에 의해 용이하게 실시 가능한 경우에도 자유실시디자인의 항변은 가능하게 되었다.[47]

조의 3의 규정에 의해 공지기술의 항변(자유기술의 항변)이라는 방법은 그 존재가치를 잃은 것으로 여겨질 수도 있으나, 특허발명에 무효 사유가 있다고 입증하는 것과 피고가 실시하고 있는 것이 공지기술 또는 그와 유사한 것이라고 입증하는 것은 다른 것으로, 입증하기 쉬운 것을 택하면 된다는 견해도 제시되고 있다. 상대적으로 자유기술의 항변이 어떠한 공지기술과 동일하다는 것만을 주장하면 되기 때문 편리한 반면, 무효의 항변의 경우 증거수집 등에서부터 시작해야 하기 때문 상대적으로 부담이 된다는 점, 자유기술의 항변은 균등론의 4요건과 별도로 존재하는 것으로 법적 의의가 있는 것으로, 가령, 발명의 구성은 용이하게 추고할 수 있지만 현저한 작용효과로 특허성을 인정할 수 밖에 없는 사례의 경우, 특허성이 인정되기 때문 무효의 항변을 주장하기는 어려우나, 피고제품만을 착목하게 되면 퍼블릭 도메인에 해당하는 것을 실시하고 있다고 하는 자유기술의 항변을 사용할 여지가 있을 것이라는 점 등에서 그 의의가 주목되고 있다.

46) 해당 판결의 판단 근거가 된 구 디자인보호법 제5조 제2항(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전까지)은 ‘의장등록출원전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 · 모양 · 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장(제1항 각호의 1에 해당하는 의장을 제외한다)은 제1항의 규정에 불구하고 의장등록을 받을 수 없다.’고 규정되어 있었다.

47) 아울러, 재판부는 원심의 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인, 확인대상디자인과 비교대상디자인의

한편, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서는 '실시'라는 용어 대신 '창작'이라는 용어를 사용하였다. 공지디자인에 근거한 자유실시디자인의 인정은 '자유실시'라는 표현과 어울리게 '쉽게 실시'라는 표현을 사용하는 것이 타당하다는 견해도 제시되고 있으나, 현재는 '창작'과 '실시'가 혼용되어 사용되고 있다.[48]

여기서 '쉽게 실시할 수 있는 디자인'이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작방법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형 · 변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다.[49]

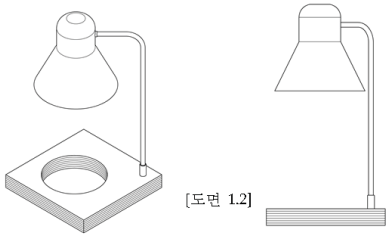
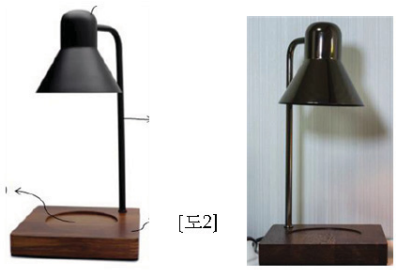
유사여부 판단에서 판단의 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사 여부를 판단하고 있다는 점에서 논리의 일관성이 없음을 지적하였다.

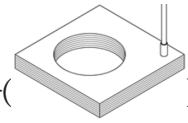
48) 정태호, "신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰", 『사법』, 제1권 제60호(2022), 664면.

49) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결에서는 '구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항의 규정 취지에 관하여 이와 같이 판시하였는데, 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2018허2427 판결, 특허법원 2018. 12. 6. 선고 2018허3598 판결, 특허법원 2019. 6. 5. 선고 2019허1872 판결 등에서도 이러한 법리에 따라 확인대상디자인이 공지디자인으로부터 용이창작 가능한 것인지 여부를 판단하고 있다.

3 대상판결(대법원 2023.2.23. 선고 2022후10012 판결)의 개요

가 등록디자인과 확인대상디자인의 대비

이 사건 등록디자인(2014. 11. 21. 출원)[50]	확인대상디자인
 [도면 1.1] [도면 1.2]	 [도1] [도2]

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 전체적으로 조명부, 연결부, 받침부로 구성되어 있는 점, ② 조명부는 원기둥과 위는 협소하고 아래쪽은 넓은 원뿔대를 결합시킨 형상인 점, ③ 연결부는 조명부와 받침부를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 연결부의 상부는 모서리가 둥근 'ㄱ'자 형으로 만곡되어 연결부의 단부가 조명부의 상단 측면에 부착되어 있는 점, ④ 받침부는 사각형상으로 되어 있고, 중앙에 향초를 받치기 위한 원형의 거치부가 형성되어 있으며, 모서리의 상면에 연결부의 하부가 부착되어 있는 점이 공통된다. 반면, ㉠ 연결부와 받침부의 결합 부위와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 원기둥 형상( )이나, 확인대상디자인은 납작한 원뿔대 형상인 점( ), ㉡ 받침부와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 거치부가 받침부 중앙을 원형으로 관통하여 형성되어 있으나(), 확인대상디자인은 거치부가 받침부 중앙에 원형

50) 구 디자인보호법 제36조 [법률 제11848호 2014. 7. 1. 시행] 적용.

으로 얕게 파여있는 형상( )인 점, ㉢ 거치부와 받침부의 측면에 형성된 무늬와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 가로 방향으로 다수의 줄무늬가 형성되어 있으나, 확인대상디자인은 아무런 무늬가 형성되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

나 소송의 경과

이 사건 소송에서는 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인을 주장할 수 있는지 여부가 문제되었는데, 해당 공지디자인은 이 사건 등록디자인의 출원인이 출원 전에 공지한 것으로, 디자인보호법 제36조 제1항의 적용의 근거가 된 것이었고, 이러한 공지디자인을 근거로 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당한다고 볼 수 있는지가 주요 쟁점이 되었다.[51]

1) 특허심판원 2020.11.16.자 2019당3599 심결

이 사건 등록디자인(제798648호)의 디자인권자인 甲은 乙을 상대로 권리범위확인심판을 청구하였고, 이에 대해 乙은 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 및 제33조 제2항에 의해 그 등록이 무효가 되어야 함을 주장하는 한편, 확인대상디자인은 비교대상디자인 1 내지 7로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다고 주장하였다.

특허심판원은 우선 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1 내지 7과 유사하여 그 권리범위가 부정되는지 여부를 살폈다. 구체적 판단에서는 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1 내지 7 각각에 대하여 공통점과 차이점의 비교를 통해 각 디자인들은 유사하지 않다고 인정하여 그 권리범위를 부정할 수 없다고 판단하였다.[52] 또한, 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지

51) 특허심판원과 특허법원에서 제출된 공지디자인 및 비교대상디자인들이 동일하지 않고, 구체적 판단 내용이 달라지고 있는바, 구체적인 내용은 소송의 경과 부분 참조.

52) 乙은 이 사건 등록디자인의 특징이라 할 수 있는 ① 내지 ④의 특징에 대해 해당 물품에 있어 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과하고, 이 사건 등록디자인과 비교대상디

여부에 관해서 살폈는데, 확인대상디자인과 비교대상디자인 1 내지 7의 공통점과 차이점을 각각 비교하여 유사하지 않다고 판단하는 한편, 확인대상디자인은 비교대상디자인 1 내지 7로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에도 해당하지 않는다고 판단하였다. 아울러, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사여부 판단에서는, 양 디자인의 공통점들은 비교대상디자인 5 내지 7에 개시되어 있고, 양 디자인의 차이점들은 자세히 보아야만 알 수 있는 미세한 차이점이거나 단순한 변형으로 그 창작적 모티브가 유사하다는 등의 이유로 양 디자인은 유사하다고 인정하여, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

2) 특허법원 2021. 12. 169. 선고 2021허1028 판결

특허심판원의 심결에 대해 乙은 불복하여 심결취소소송을 제기하였는데, 자유실시디자인에 해당한다는 주장과 관련하여 이 사건 등록디자인을 그대로 구현한 제품 디자인을 공지디자인으로 추가로 제시하였다.[53]

특허법원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 상이하다고 판단하였는데, 구체적 판단에서는 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서 공지부분의 중요도를 낮게 보고, 선행디자인들에 공지되지 않은 부분들을 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이라 인정하고, 이러한 지배적 특징들 중 일부를 확인대상디자인이 채택하고 있지 않음을 이유로 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다.[54]

자인들 사이에 미세한 차이만 있을 뿐이며, 이러한 차이는 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 사소한 변형에 불과하여 이 사건 등록디자인은 무효임이 명백하다고 주장하였다. 이에 대해 심판부는 디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비, 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 한다는 등의 이유를 들어 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 유사하지 않다고 판단하였다. 아울러, 창작비용이성 여부에 대한 판단은 그 등록이 무효로 되기 전에 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없다고 하여 피청구인의 주장을 받아들이지 않았다.

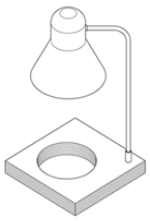
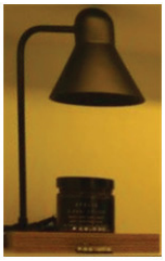
53) 특허법원은 乙이 제시한 공지디자인을 이 사건 등록디자인이 그대로 구현된 제품의 디자인으로 이 사건 등록디자인의 특징을 모두 구비하고 있는 것으로 인정하였다. 이 사건 공지디자인은 2014. 7. 3. 공지되었고, 피고는 그로부터 6개월 내인 2014. 11. 21.에 이 사건 공지디자인을 디자인등록출원하였다.

54) 특허법원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점 ①, ②, ③ 및 차이점 ㉠은 선행디자인 5에 공지되어 있기 때문에 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 판단하였다. 또한,

한편, 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변은 허용되는 것으로 판단하였는데,[55][56] 신규성 상실의 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 예외 규정을 도입한 취지에 반하게 되며, 디자인보호법은 이러한 예외를 인정받을 수 있는 시기를 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는바 이러한 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있기 때문이라는 이유를 들어 이 사건 공지디자인을 기초로 하는 자유실시디자인의 항변을 인정하였다. 결국 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 이 사건 공지디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로 이 사건 등록디

공통점 ④의 받침부 중앙의 원형의 거치부의 특징은 선행디자인 1, 2, 4 등에 공지되어 출원 전 공지된 것으로 보는 한편, 이러한 특징은 기능을 수행하는 기본적이고 흔하게 사용되어 왔던 디자인에도 해당하므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 판단하였다. 이러한 점들을 고려하면, 양 디자인의 공통점 ④와 차이점 ㉡, ㉢이 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징에 해당하며, 이러한 특징들이 출원 전에 공지된 선행디자인들과 구별되는 새로운 심미감을 야기하는 부분에 해당하고, 이러한 부분들 중 차이점 ㉡, ㉢은 확인대상디자인이 채택하지 않아 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다.

55) 특허법원은 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 확인대상디자인과 공지디자인과의 공통점 및 차이점은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에서 판단했던 내용과 일부 표현의 차이는 있으나, 실질적으로 동일하게 인정하였다. 다만, 구체적인 검토에서 차이점 ㉠~㉢에 관해서는 해당 디자인 분야에서 흔한 창작방법 내지는 공지디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 정도의 수준의 것으로 인정함으로써, 확인대상디자인은 공지디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하는 것으로 판단하였다.

이 사건 등록디자인	확인대상디자인	공지디자인(이 사건 등록디자인의 실시제품)
		
비유사		
	확인대상디자인은 공지디자인으로부터 용이하게 창작 가능	

56) 2019. 11. 14.에 권리범위확인심판이 청구된 이후, 2021. 6. 13.에 등록무효심판이 청구되었고, 원심인 특허법원 2021. 12. 16.선고 2021허1028 판결이 있은 이후, 특허심판원 2022. 1. 28.자 2021당1794심결에서 신규성 상실의 예외 주장이 인정되었다.

자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.[57]

3) 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결(대상판결)

이에 피고 디자인권자인 甲이 불복하여 상고하였으나, 대법원은 원심판결에 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인에 관한 법리를 오해한 잘못은 있으나, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 결론은 정당하다고 판단하여, 상고기각 판결을 선고하였다.

다 대상판결의 판시

대법원은 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부에 관해서 명확한 판단 기준을 제시하였다. 즉, 자유실시디자인의 법리에 관해서 "기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다."고 판시하였다. 그 이유에 관해서는 "제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실의 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의

57) 한편, 이 사건 등록디자인의 등록무효심판에 대한 심결취소소송인 특허법원 2023. 4. 13. 선고 2022허2400 판결에서는 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지에 대한 판단을 하였는데, 용이창작에 대한 구체적 판단에서는 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 공통점은 중요도가 낮은 부분에 그친다고 판단하는 한편, 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 거치부의 개구된 형상과 받침부 및 거치부 내·외곽에 형성된 실선 무늬로 보고, 이러한 부분들은 그 디자인 분야의 일반적인 경향도 아니고, 선행디자인들에 개시되어 있지 않아 구 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 판단하였다.

결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다."라고 설시하였다.

4 신규성 상실의 예외 규정의 주요쟁점에 대한 검토

가 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건

(1) 문제의 소재

신규성 상실의 예외 인정은 어디까지나 원칙에 대한 예외이므로 디자인창작자를 과대하게 보호하거나 일반 공중에게 불이익을 주지 않도록 일정한 절차적 제한을 둘 필요가 있다는 점에 근거하여, 디자인이 공지된 경우 그 날부터 12개월 이내에 출원될 것을 요하며, 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 시기를 제한해 왔다.[58] 동시에, 신규성 상실의 예외 주장의 취지를 적은 서면과 증명서류를 일정기간 내에 특허청에 제출할 것을 요구하는 절차적 요건도 구비되어 있었다. 이러한 절차적 규정은 본 규정의 효과가 과대한 보호에 의해 제3자의 이익을 해치지 않도록 그 절차적 요건상의 제한을 법률로 규정하고 있는 것으로, 제3자와의 이익을 해하는 등의 사유가 아니라면 제도의 입법 취지대로 창작자 등의 권리를 보호하기 위해 디자인보호법상 합리적인 법익을 충족한 디자인권으로서의 정당한 효과를 유지시키도록 해야 하는 것으로 이해되어 왔다.[59]

58) 정태호, 앞의 글(주 5), 120면.
59) 정태호, 앞의 글(주 5), 121면.

대상 판결에서도 “제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실의 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다.”라고 하여, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인의 주장을 허용하는 것은 디자인권자와 제3자 사이의 형평에 맞지 않다고 판단하였다.[60]

한편, 실제 거래 시장 등에서의 신규성 상실의 예외의 주장시기에 관한 문제점을 개선하고, 디자이너 등의 창작자의 보호 차원에서 신규성 상실의 예외 인정의 필요성이 크다는 점을 반영하여, 2023. 6. 20. 법률 제19494호로 일부 개정에 의해 특허청에 대한 서류제출에 관한 절차적 규정이 삭제된 현재로서도, 대상판결에서 근거로 제시하고 있는 제3자의 이익균형이 유지되고 있는 것인지에 대한 재평가가 필요한 시점이다.[61] 나아가, 등록디자인의 보호 기간이 출원일로부터 20년이라는 점을 고려하면, 개정 전 디자인보호법 제2항의 절차적 규정의 적용은 향후 일정 기간 동안 유효할 것으로, 실무적으로는 출원 시기 별로 해당 절차적 규정들이 어떻게 적용될 것인지에 대한 확인이 필요할 것이다.[62]

60) 이 사건 등록디자인은 2014. 11. 21. 출원되어 구 디자인보호법 제36조 제2항(2013. 5. 28. 법률 제11848호)이 적용된다.

61) 참고로, 단순하게 특허 등과 비교해서 신규성 상실의 예외에 관한 주장시기가 디자인보호법에서는 지나치게 확대되어 있으므로, 제3자의 이익을 해할 개연성이 더 크다는 주장은 디자인보호법상의 특수성과 입법 목적을 고려하지 않은 판단이라는 비판이 있다[정태호, 앞의 글(주 48), 696면].

62)

	법률 제5354호 (1998. 3. 1. 시행)	법률 제11848호 (2014. 7. 1. 시행)	법률 제14686호 (시행 2017. 9. 22.)	법률 제19494호 (시행 2023. 12. 21.)
시기	공지일로부터 6개월	공지일로부터 6개월	공지일로부터 12개월	공지일로부터 12개월
절차	출원 시 그 취지 기재, 30일 이내 증명서류 제출 (다만, 자기의 의사에 반하여 공지된 경우에는 그러하지 아니함)	1. 출원 시 그 취지 기재, 30일 이내 증명서류 제출 2. 의견서 제출 시 3. 이의신청에 대한 답변서 제출 시 4. 무효심판에 대한 답변서 제출 시	1. 출원 시 그 취지 기재, 30일 이내 증명서류 제출 2. 거절결정 또는 등록결정 전 3. 이의신청에 대한 답변서 제출 시 4. 무효심판에 대한 답변서 제출 시	삭제

(2) 주요국의 운용

(가) 일본

2024년 1월 1일 이후 시행되는 개정 일본 의장법 제4조 제3항에서는 "동일 또는 유사한 디자인에 대해 디자인등록을 받을 권리를 가진 자의 2 이상의 공개행위가 있는 경우에는 그 증명서의 제출은 당해 2 이상의 행위 중 최선(最先)의 일에 행해진 것의 하나의 행위에 대해서 하면 충분하다."라는 단서를 추가하는 개정을 하여 디자인 신규성 상실의 예외의 적용에 관한 증명 절차의 간소화를 도모하였다.[63] 증명서의 제출은 행위별로 해야 하는 것이 원칙이었으나, 출원인에게 큰 부담이 되는 점이 지적되어, 증명서 제출 부담을 경감하기 위한 목적으로 개정된 것이다.

일본은 법 개정에 의해 관련의장으로 등록 가능한 기간이 10년으로 연장됨에 따라, 관련의장제도는 새로운 신규성 상실의 예외로서의 측면도 있는 것으로 평가되는 한편, 관련의장제도의 경우 대기업 등이 이용하는 경우가 많기 때문에, 신규성 상실의 예외 주장과 관련하여 실질적인 이용이 많은 개인 출원인들의 편의를 위해서 절차적 요건을 간소화하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되어 왔다.[64]

(나) 미국

미국에서 디자인을 출원하려면 디자인 특허로 출원을 해야 하고, 따라서 특허법의 적용을 받는다. 미국은 2011년 특허법이 개정되어 선발명주의로부터 선원주의로 변경되었는데(미국특허법개정안, AIA), 선원주의로 이행함에 따라, 신규성(미국 특허법 제102조) 및 비자명성(우리나라의 진보성, 미국 특허법 제103조)의 판단기준이 발명일이 아닌, 출원일이 되었다.[65] 여기서 판단기준이 되는 출원일은 '유효출원일(effective filing date)'로, 미국에서 특허 또는 출원된 최선의 현실 출원일

63) 일본의 경우 구 의장법(1921년법)에서는 박람회에 출품한 경우에만 인정하는 정도로 예외 사유를 한정하였었다. 널리 예외 사유를 인정하면서까지 의장을 보호할 필요가 없다고 여겨져 특허법에서 인정되는 사유보다 좁게 인정되었었으나, 이후 사회 실정에 맞지 않는다는 인식 하에 점차 인정 범위가 확대되게 되었다.

64) 青木大也, "意匠法改正をめぐる諸問題(1)", 『知的財産法政策学研究』, Vol. 55(2020), 235면.

65) Leahy-Smith America Invents Act(AIA)는 2011년 9월 16일 오마바 대통령의 서명에 의하여 개정된 법률로서 2013년 3월 16일에 시행되었다.

또는 최선의 외국·PCT 출원에 관한 우선일(미국 특허법 제100조)을 의미한다. 선발명주의 하에서는 신규성 등의 특허요건을 판단하는 시점은 발명시를 기준으로 하기 때문에, 발명 이후의 공개 행위가 신규성 등의 판단에 영향을 미치지는 않았으므로 특허출원일 이전의 공개행위에 대하여 공지예외적용을 인정하는 규정이 원칙적으로 필요하지는 않았다.[66] 하지만, 선출원주의를 채택하게 된 미국은 선출원주의 하에서의 문제점을 극복하기 위하여 공지예외적용제도(Grace Period; 유예기간)를 도입하게 되었다.[67] 또한, 공지예외적용제도가 적용되는 유예기간은 1년이나, AIA 개정법에서는 신규성 등의 특허요건을 판단하는 기준 시점이 미국출원일에서 유효출원일로 변경됨으로써, 조약우선권을 주장하면서 미국에 특허출원을 하는 경우에는 우선일을 기준으로 공지예외 기간이 계산되므로 공지예외 기간이 최대 2년까지 연장되는 효과가 나타난다.[68]

미국은 공지예외를 적용받기 위한 취지의 기재나 증명서류의 제출 등을 요구하고 있지 않다. 즉, 발명자가 최선의 공지일로부터 1년 이내에 특허출원을 한 것으로 충분한 것이지 따로 공지예외적용 주장 시기를 정할 필요가 없다고 보고, 공지와 관련된 증명서류도 심사관이 필요하다고 판단되어 요청하는 경우에 한하여 제출할 수 있도록 하여 출원인의 편의를 도모하고 있다.[69]

(다) 유럽

유럽 공동체디자인 규정(Community Design Regulation, CDR) 제7조 제1항에서는 등록디자인의 신규성(제5조)과 독자성(제6조)의 평가에 사용될 수 있는 선

66) 홍정표, “공지예외 제도의 문제점 및 개선방안”, 『지식재산연구』, 9권 4호(2014), 44면.
다만, 선발명주의 하에서도 발명 이후에 이를 조속히 특허출원으로 유인하기 위한 장치는 필요하므로, 구특허법 제102조(b)에서“미국에서의 특허출원일보다 1년 이상 전에, 그 발명이 국내외에서 특허를 받았거나 반포된 간행물에 게재되었거나 또는 미국 내에서 일반 공중에 의해 사용되거나 판매된 경우에는 특허를 받을 수 없다”고 규정하였다. 이 규정은 발명 이후에 조속한 특허출원을 하지 않으면 특허를 받을 수 없도록 하는 규정이기 때문에, 이 규정이 공지예외적용제도와 관련된 규정이라고 보기는 어렵지만 내용적인 측면에서는 공지예외적용제도와 비슷한 점이 있다고 설명된다[윤기승, “특허법상 공지예외적용에 관한 연구”, 『국제법무』, vol.11, no.1(2019), 10면].

67) 윤기승, 앞의 글(주 66), 10면.

68) 홍정표, 앞의 글(주 66), 46면.

69) 정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”,『정보법학』, 제17권 제2호(2013), 41면[윤기승, 앞의 글(주 66), 11면 재인용].

행디자인의 범위에 관하여 규정하고 있다. 공동체디자인 규정 제5조(신규성)에서는 공중이 이용할 수 있는 디자인과 동일하지 않은 경우 신규한 것으로 간주한다고 규정하는 한편, 디자인의 동일성 판단과 관련해서는 중요하지 않은 부분에서 차이가 있는 경우에도 동일한 범주 내에 포함하는 것으로 명시하고 있으며, 신규성의 판단 기준일은 출원일 또는 우선일로 규정하고 있다.[70] 여기서 공중이 이용할 수 있는 디자인에 관해서는 제7조에 디자인이 등록 후 또는 그 외의 방법으로 간행물로 반포되었거나[71], 전시되었거나, 상업적으로 사용되었거나, 그 외의 방식으로 공개되었을 때에는, 그 디자인은 공지된 것으로 간주된다고 규정하고 있다.

한편, 공개가 해당 커뮤니티 내 관련 업종에서 통상적으로 활동하는 전문 분야의 사람들에게 정상적인 사업 과정에서 합리적으로 알려지지 않았을 경우는 예외로 하는 것으로 규정하고 있다.[72] 이러한 예외 규정은 상대적 신규성으로 설명되고 있는데,[73] 일정한 예외 사유에 해당하는 경우에 아예 공개되지 않은 것으로 취급

70) 유럽 공동체 디자인규정의 제5조 제2항은 디자인의 특징이 중요하지 않은 세부 사항만 다른 경우도 동일한 것으로 간주됨을 규정하고 있으며, 제6조 제1항은 통상의 정보를 가지는 사용자에게 주는 전체적인 인상이 출원일(우선일) 전에 공중이 이용 가능하게 된 의장과 전체적인 인상이 다른 경우에는 독자성(individual character)이 있는 것으로 간주하도록 규정하고 있으며, 제2항은 이러한 독자성을 평가하는 경우 디자인을 개발할 때의 디자이너의 자유도를 고려하도록 규정하고 있다.

71) 등록에 의하여 간행된 경우만 디자인의 공개에 해당하며(if it has been published following registration), 신문, 잡지, 카탈로그, 비디오(전자기록매체) 등의 간행을 통한 공개는 '그 외의 방법으로 간행'된 경우에 해당한다[David Stone, op. cit., pp.164, 168-169(안원모, "디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도에 관한 고찰, 『산업재산권』, 제71호(2022), 155면 재인용)].

72) 제7조 공지 (공개)

1. 제5조 및 제6조를 적용함에 있어서, 디자인이 등록 후 또는 그 외의 방법으로 간행물로 반포되었거나, 전시되었거나, 상업적으로 사용되었거나, 그 외의 방식으로 공개되었을 때에는, 그 디자인은 공지된 것으로 간주된다. 다만, 이러한 공개가 해당 커뮤니티 내 관련 업종에서 통상적으로 활동하는 전문 분야의 사람들에게 정상적인 사업 과정에서 합리적으로 알려지지 않았을 경우는 예외로 한다. 디자인이 명시적 또는 암묵적인 비밀 유지 조건 하에서 제3자에게 공개된 경우에는, 이를 단순히 대중에게 공지된 것으로 간주하지 않는다.
2. 등록 공동체 디자인 하에서 디자인 보호를 청구하는 그 디자인이 다음과 같은 이유로 공지된 경우에는 그 공지는 제5조 및 제6조를 적용함에 있어서 고려하지 않는다:
   (a) 디자이너, 그의 승계인, 또는 제3자가 디자이너나 그의 승계인의 정보 제공이나 조치로 인해 디자인이 대중에게 공지된 경우;
   (b) 출원일 또는 우선권이 청구된 경우, 우선권일 전 12개월 동안 내에 디자인이 대중에게 공지된 경우.
3. 제2항은 디자인이 디자이너나 그의 승계인에 대한 부당한 행위의 결과로 대중에게 공지된 경우에도 적용된다.

73) 절대적 신규성은 지역이나 시간의 제한 없이 디자인이 공개된 적이 있다면 그 디자인은 신규성이 없는

하는 점에서, 공개는 되었으나 일정 요건 하에서만 신규성 상실의 예외를 인정하는 신규성 상실의 예외 제도와는 다른 것으로 설명된다.[74] 유럽연합은 유럽공동체디자인 제도 창설 당시 공개 예외 제도를 도입함으로써 신규성 또는 독자성의 판단에서 인용되는 선행디자인의 범위에 제한을 두고자 하였는데, 제도 창설 당시 유럽연합 회원국들은 신규성 판단의 지역적 기준과 관련하여 입장의 차이가 존재하였다. 대립되는 논쟁의 결과 원칙적으로 세계적으로 통용되고 있는 신규성 기준을 채택하되, 그 기준을 다소 완화하여 공개의 예외를 인정하기로 한 것이다. 즉, 유럽 공동체 내 관련 당사자들에게 합리적으로 알려지지 않은 모호한 공개에 대해서는 공개의 예외를 인정하기로 하였고, 이에 따라 제7조 제1항에서의 공개 예외 규정은 세계적 신규성 기준과 지역적 신규성 기준 사이의 타협점이라 할 수 있다.[75]

아울러, 유럽의 경우도, 이러한 공지예외 규정을 적용받기 위한 별도의 절차적 요건은 없고, 다툼이 발생했을 때 추후에 입증하는 방식으로 운용되고 있다.

(3) 개선점: 디자인보호법 특수성에 따른 완화된 절차적 요건의 운용

법 규정의 적용을 받으려는 입장에서는 절차적 요건과 같은 형식적 요건의 불비에 의해 본래 보호되어야 할 발명 등에 대해 신규성 상실의 예외 규정이 적용되지 않는 것은 바람직하지 않다 할 것이다. 절차적 요건은 자기 책임 하에 이루어지는 것으로, 절차에 불비가 있다 하더라도, 그 불비에 의한 불이익은 자기의 행위에 따른 결과인 것으로 생각할 수 있으나, 처리해야 하는 절차가 많고 복잡하게 되는 경우가 존재하고, 본인 이외의 자에 의한 공개 리스크가 높으며, 그 모든 것을 파악하는 것이 곤란한 경우도 존재하는 점을 고려하면, 신규성 상실의 예외 적용을 위한

것으로 취급하는 것을 의미하나, 상대적 신규성은 디자인의 공개가 있다고 하더라도 일정한 사유에 해당하는 경우에는 그 디자인은 공개되지 않는 것으로 취급하는 것을 의미한다[안원모, 앞의 글(주 71), 159면].

74) 안원모, 앞의 글(주 71), 159면.

75) 가령, 공동체디자인 제도가 창설되기 전 덴마크, 이탈이라, 스페인 스웨덴 등은 세계적 신규성 기준(소위 '국제주의')을 채택하고 있었고, 독일, 영국, 베네룩스 3국 등은 지역적 신규성 기준(소위 '국내주의')을 채택하고 있었다. 세계적 신규성 기준에 대해서는 부유한 거대 기업은 세계 오지의 지역 및 고대 자료가 보관되어 있는 박물과관 등을 뒤져 선행의 자료를 찾아낼 수 있기 때문에 소송에 유리한 입장에 설 수 있다는 등의 지적이 있었고, 지역적 신규성 기준에 대해서는 이미 외국에서 공지된 디자인이 유럽연합에 신규한 디자인으로 등록받을 수 있게 되어 외국의 경제주체들에게 이익을 주게 된다는 등의 지적이 있었다. 구체적 내용은 안원모 앞의 글(주 71), 160-161면 참조.

절차 완화는 허용되어야 한다 할 수 있다.[76] 반면, 제3자의 입장에서는, 완화된 신규성 상실의 예외 규정이 적용됨으로써, 그 사실이 특허공보 등에 등록되지 않은 사례가 증가될 것이 예상되기 때문에, 신규성 상실의 예외 적용을 위한 절차의 완화는 바람직하지 않다는 생각을 할 수 있다.[77] 하지만, 신규성상실의 예외 적용을 위한 증명서류 등의 제출 절차와 같은 형식적 요건이 완화되었다 하더라도, 자기공지 이후에 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 유지되고 있고 본래 보호되어야 할 디자인 등이 보호되는 것이기 때문에, 제3자의 불이익은 한정적이라 볼 수 있으며, 또한, 제3자에게는 대상 디자인 등에 관한 신규성 상실의 사유를 발견한 경우에, 정보 제공 등에 의해 그 사실을 특허청에 제시할 수 있는 길이 열려 있기 때문에, 제3자의 불이익을 고려한다 하더라도 신규성 상실의 예외 적용을 위한 절차적 완화에 따른 불이익은 한정적이라 할 것이다.[78]

아울러, 미국이나 유럽과 같이 '12개월 이내 출원'이라는 요건 이외에는 신규성 상실의 예외 적용을 위한 특별한 절차가 요구되지 않는 국가도 존재하고, 또한 정보화 사회의 진전에 따라, 일단 개시된 디자인 등에 관한 정보가 순식간에 세계로

76) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 81-82면.
일본의 산업구조심의회 지적재산분과회 제13회 의장제도 소위원회의 당면 검토과제로서, 신규성상실의 예외 적용 절차가 올라와 있었다. 특허청 홈페이지에 공표된 자료에 따르면, 심사에서 신규성 상실을 이유로 거절된 출원 중 약 20%가 자기의 1년 이내의 공개의장(내외 공보 제외)에 의해 거절이유가 통지되었고, 그 중 약 3분의 1은 출원 시 예외적용서면 및 예외적용증명서를 제출하였음에도 불구하고, 증명이 불충분하다는 이유로 거절이유가 통지되었다고 한다. 이러한 문제점들이 지적되는 상황에서 관련 절차의 완화를 검토하기에 이르렀다. 아울러, 해당 공표자료에 따르면, '최근, 의장의 신규성 상실의 예외 규정의 신청 건수·비율은 증가 경향에 있는데실제 2020년 신규성상실예외증명서류제출 건수는 특허가 4,128건(약1.3%) , 의장이 2,594건(약8.2%)으로 보고되었다), 그 이유로서 디자인 개발의 경우 하나의 디자인 컨셉에서 디자인이 다양하게 변형되고, 관련된 디자인이 동시기에 창작되기 때문에, 다양하게 변경된 디자인들이 동시기에 다수 공개되기 쉽고, 그러한 모든 공개에 대해 디자인의 증명이 필요하다. 특히, 카탈로그 배포 및 전시회 출품 등의 종래의 마케팅에서의 공개뿐만 아니라 여러 SNS를 활용한 제품 PR이 활성화되고 있고, 다양한 루트를 통해 판매되는 등, 단일 출원과 관련된 공개의 형태가 다양화되고 복잡하게 되고 있는 상황이다. 특히 중소기업에서 클라우드 펀딩처럼 디자인을 공개하고 투자를 모으고 나서 제품화를 결정하거나 제조 위탁 및 공동 개발 과정에서 외부의 협력 기업이나 소비자와 협력하여 제품을 완성하는 등 개발과정에서 공개하는 기회도 늘고 있다. 하지만, 중소·벤처 기업을 중심으로 한정된 기간 내에 모든 공개 사실을 포괄적으로 증명하는 것은 매우 어렵다는 목소리가 있다.'고 보고되었다. [産業構造審議会知的財産分科会, 意匠の新規性喪失の例外適用手続について, 第13回 意匠制度小委員会, 2022, 6-7면].

77) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 82면.

78) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 82면.

확산되고, 게다가 출원인의 의도와는 관계없이 정보가 확산되는 현상도 발생되기 때문에, 그러한 모든 확산된 정보를 관리할 것을 출원인에게 요구하는 것은 출원인에게 과도한 부담으로 이어지게 되고, 나아가서는 디자인 등의 보호가 불충분하게 될 우려가 있기 때문에, 신규성 상실의 예외 규정과 관련하여 증명서류 등의 제출 절차를 생략하는 것은 바람직하다고 볼 수 있다.[79]

우리나라는 신규성 상실의 예외의 인정이 창작자의 공지디자인에 대한 독점적인 권리화를 강화시키는 것과 연결되는 입법으로 확대되어 왔음을 확인할 수 있으며, 신규성 상실의 예외의 의미가 일본 의장법과 비교해 볼 때도 더욱 창작자 등 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 공지디자인에 대한 독점권의 부여라는 법적 지위와 연결되고 있다고 평가할 수 있다.[80] 디자인은 사람들이 접하게 되면 쉽게 모방될 가능성이 있으며, 판매, 전시, 견본의 배포 등을 통해 수요를 타진해 보는 것이 일반적인 점, 발명은 공개되면 사회의 기술 수준의 일부가 되고, 그 위에 기술 활동이 축적되는 것이기 때문에, 공개된 이후에 특허를 부여하는 것은 기술 활동을 저해하는 것이 되기 때문에 널리 예외를 인정하는 것이 법의 목적에도 부합하지 않으나, 디자인의 경우 공개된 디자인이 축적됨으로써 디자인 산업이 발전하는 것이 아니고,[81] 비밀디자인제도나 관련디자인제도 등을 통해 제3자와의 균형보다는 창작자 보호에 좀 더 비중을 두어왔다는 점에서도 특허와 비교하여 상대적으로 예외를 널리 인정할 수 있을 것이다. 특허나 실용신안등록과 비교하여 개인 출원의 비율이 상대적으로 높다는 점에서도, 창작자의 구제적인 성격은 특허제도에서의 신규성 상실의 예외 규정과 비교하여 큰 의의를 가진다고 할 수 있을 것이다.

한편, 주의해야 할 점은 신규성상실예외 주장이 국내에서의 특허청에 증명서류 제출 요건 등의 절차적 요건이 완화되었다 하더라도 해외로의 진출을 고려하고 있는 경우에는 공개에 신중을 기할 필요가 있을 것이다. 즉, 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받는다 하더라고 그 효과는 국내에 한정되게 되는데, 가령, 일본과 같은 나라는 여전히 자기 의사에 의한 공지의 경우 출원일로부터 30일 내에 관련 증명서류를 제출할 것을 요하고 있기 때문 공지에는 신중을 기할 필요가 있을 것이다.

79) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 84면.

80) 정태호, 앞의 글(주 5), 113-114면.

81) 디자인 트렌드를 보면, 미니멀 디자인이라든지 레트로 디자인 등은 오히려 디자인을 최소화하고 과거로 돌아간다는 점에서, 특허와 같이 기술 활동이 축적되어 기술이 진보된다는 개념과는 다르다 할 것이다.

나 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건

(1) 문제의 소재

신규성 상실의 예외 규정에서, 그 예외 사유가 있는 경우 특허청에 그 취지나 증명서류를 제출하게 하는 형식적인 절차적 요건은, 공지 후 12개월 이내에 출원해야 하는 기본적인 절차적 요건이나, 공지 형태 또는 범위 등의 실체적 요건과 비교하면, 그 중요성은 덜하다고 볼 수 있다. 특히 대상판결 이후 최근 법 개정으로 인하여 국내의 디자인보호법에서 신규성 상실의 예외 규정의 형식적인 절차적 요건이 사실상 폐지되었다고 볼 수 있고, 공지 후 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 세계적인 표준으로 당분간 변경의 가능성은 거의 없는바, 향후에는 그 실체적 요건에 관한 운용이 더 중요해질 것으로 보인다.

실체적 요건 중에서도 가장 논란이 되는 것은, 신규성 상실의 예외 주장이 가능한 공지디자인의 범위일 것이다. 디자인보호법 제36조 제1항의 전단에서는 '디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우'라고 하여, 동일한 범위로 한정하는 것으로 이해할 수도 있으나, 전술한 바와 같이 2007. 1. 3. 개정 디자인보호법(법률 제8187호, 시행 2007. 1. 3.)에서 '그 디자인 또는 이와 유사한 디자인은'을 '그 디자인'으로 수정하면서 양 디자인이 동일 또는 유사한지 여부에 상관없이 출원디자인이 소정의 요건만 충족하면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있게 되었다. 아울러, 제36조 제1항의 후단에서 '같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때'라고 되어 있어서, 유사 범위를 넘는 비유사한지 여부를 판단할 필요가 없을 것으로 보인다. 다만, 제36조에서는 '디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이'라고 규정되어 있다는 점에서, 타인에 의해 공개된 디자인의 경우, 특히 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자로부터 유래하지 않거나 타인에 의해 개량 등이 이루어진 경우 등에 관해서는 판단이 쉽지 않다는 점에서, 특허청 등의 기관에 그 판단을 기대할 밖에 없는데, 이런 점에서 제3자에 대한 정보제공, 이의신청, 무효심판청구 등에 대한 부담도 발생할 수 있을 것으로 보인다.

한편, 신규성 상실의 예외가 인정되는 공지디자인의 범위에는, 디자인 등록을 받

을 권리를 가진 자의 내외국 특허청에서의 출원행위에 기인하여 특허공보 등에 게재한 것이 제외된다는 점을 현행 디자인보호법 제36조 제1항 단서 규정에 명문상 명확하게 규정한 것은 바람직해 보인다. 신규성 상실의 예외 규정은 자신의 디자인을 출원하기 전에 공개해버린 디자인권자 등을 염두에 두고 규정된 것이기 때문에, 그 제도의 취지를 고려하면, 출원 행위에 기인하여 등록공보 등에 게재되어 신규성을 상실한 디자인을 적용대상으로 할 필요가 없는 것이다. 그 이유로서, 디자인 공보 등을 적용대상으로 하게 되면, 해당 규정을 이용하여 디자인권 기간을 실질적으로 연장할 가능성이 있기 때문 제도를 악용할 우려가 있는 것이다.[82)]

이하에서는 신규성 상실의 실체적 요건과 관련하여, 국내 디자인보호법 상 명문의 규정이 없고 가장 논란이 될 수 있는 사안인, 디자인의 창작자가 공개한 것에 기인하여 타인이 공개한 경우 어떻게 취급해야 하는지, 그리고 신규성 상실 예외가 적용되는 공지디자인의 범위에 대하여, 주요국의 운용을 검토한 이후 국내의 바람직한 운용에 대하여 검토해 보고자 한다.

(2) 주요국의 운용

(가) 일본

일본 의장법 제4조 제2항에서는, “의장등록을 받을 권리가 있는 자의 행위에 기인하여 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 의장은, 거기에 해당하게 된 날부터 1년 이내에 그 자가 한 의장등록출원과 관련된 의장에 대한 제3조 제1항(신규성) 및 같은 조 제2항(창작 비용이성)의 규정의 대해서는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 되지 아니한 것으로 본다.”고 규정하고 있는바, 신규성 상실 예외 규정이 적용되는 공지디자인과 출원디자인 사이의 동일·유사 정도의 범위에 대해서는 명확하게 규정하고 있지 않다.

東京高判 平成8. 2. 28. 平7(行ケ)159 단자반 사건에서는 신규성 상실의 예외 주장의 적용에 있어서 동일이 아닌 유사한 범위까지 인정해야 하는가에 관해서 다음

82) 미국이나 유럽의 경우 출원일 또는 우선일로부터 12개월 이내로 규정하고 있고, 미국의 경우 공보 등에 게재된 경우에도 인정되고 있다는 점에서 우리와는 다르게 규정되어 있다. 다만, 등록공보 등에 게재된 경우에도 신규성 상실의 예외 규정을 인정하게 되면, 조약 우선권 주장을 이용한 해외 기업들에게 상대적으로 기간의 연장이라는 효과를 부여하게 된다는 점에서, 등록공보 등에 대해서도 신규성 상실의 예외를 인정할지 여부는 산업발전의 정도에 따라 선택 가능한 사항이라 생각된다.

과 같이 설명하였다. 공개된 의장이 존재하는 것을 이유로 등록을 받을 수 없는 경우 출원인에게 가혹하며, 디자인 업계의 실정과도 맞지 않으며, 신규성상실의 예외를 규정한 입법 취지에 비추어, 의장의 '동일'과 '유사'가 별개의 개념이라는 것을 전제로 하더라도, 심결에서 말하는 '동일'이란 법률상의 개념으로서 단순히 물리적으로 형태가 완전히 일치하는 것만이 아니라, 형태에 있어서 미세한 차이가 있더라도 동조의 입법취지에 적합한 한도에서 사회통념상 의장의 표현으로서 동일한 범위로 이해되어야 한다고 판시하였다. 이러한 재판부의 '사회통념'에 따라 판단해야 한다는 부분에 관해서, 구체적 기준을 제시하지 못 했다는 지적도 있으나,[83] 대비되는 양 의장의 기본적 구성태양 및 각부의 구체적인 태양이 공통되는 것으로, 양자의 차이점이 '매우 흔한 태양의 것', '아무런 의장적 특징이 없는 것', '형태 전체로서 보아 눈에 띄지 않는 미세한 차이', 또는 '유저의 요구에 따라 적절히 변경할 수 있는 정도의 형태상 특단의 특징이 없는 차이에 불과한 것'이라 하여 동일성 판단의 구체적 기준으로서 고려되어야 할 사항을 명확히 한 것이라고도 볼 수 있다.[84] 의장의 경우 특허법상 발명과는 달리 한 번 사람의 눈에 띄게 된 것만으로도 공지가 되는 점, 디자인에 관한 시험을 공중이 있는 장소에서 할 필요가 있는 경우가 있는 점, 계절적 유행에 따른 의장의 경우 의장출원 전에 판매할 필요가 있는 점, 디자이너의 세계에서는 공모전 등이 많은 점, 디자인의 창작의 과정에서 시장조사를 할 필요가 있는 점 등이 있는데,[85] 의장에 관한 이러한 사정들을 고려하면, 출원 전에 공개된 의장이 출원된 의장과 미묘한 점에서 차이가 있는 일은 많을 것으로 추정할 수 있을 것이다.[86]

83) 茶園成樹, "意匠法4条2項における公開された意匠と出願意匠との同一性", 『特許研究』, 24(1997), 48면[三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著),『判例意匠法―三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念』, 発明推進協会, 1999, 164면(大瀬戸・豪志 집필부분 "意匠法4条2項における意匠の同一性") 재인용].

84) 三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著), 앞의 글(주 83), 164면[大瀬戸・豪志 집필부분].

85) 三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著), 앞의 글(주 83), 105-106면[牛田利治 집필부분 "意匠法4条2項と類似の意匠の公表"].

86) 東京高裁・平成4年9月8日決定・平成4年(ラ) 第19号 (意匠権侵害差止仮処分申請却下決定に対する抗告事件) 自動車用ホイール事件에서는 신규성 상실의 예외 주장의 적용이 등록의장과 유사한 의장에도 적용 가능한지가 문제가 되었는데, 재판부는 동일인이 상호 유사한 의장을 동시에 창작한 경우에는 본래 의장등록을 받을 권리는 양 의장에 관해 별개로 발생하며, 법적으로 동등하게 평가되어야 한다고 보고, 본 규정의 취지를 고려하여, 의장등록을 받을 권리를 가지는 자가 동일인의 경우에는 동시에 공표된 유사한 의장에 관해서도 본 규정이 적용되어야 한다고 판단하였다.

다만, 최근 판결례에서는 신규성 상실의 예외 규정의 인정 범위를 매우 제한적으로 판단하고 있다. 知財高裁 平成30. 7. 19. 平9(行ケ)10234 코트 사건에서는 공개의장과 인용의장(출원인이 공개한 의장)은 실질적으로 동일하지 않아 신규성 상실의 예외 규정의 적용의 대상이 되지 않는다고 판단하는 한편, 본건 등록의장은 인용의장과 유사하여 신규성이 상실된다고 판단하였다.[87] 知財高裁 令和5. 12. 25. 令5(行ケ)10071 가방 사건의 판결에서도 증명서에 기재된 의장과 인용의장은 동일해야 할 것을 요하고, 가령 차이가 있는 부분이 있다 하더라도 '물품의 성질이나 기능에 비추어 실질적으로 동일한 것으로 충분히 이해할 수 있는 범위 내'의 차이일 것을 요한다고 판시하였다. 구체적으로 해당 판결에서는 장식 단추를 다는 것 자체는 가방이라는 물품의 성질 상 흔한 것이라 하더라도, 그 수나 배치의 태양은 다양하고, 가방의 미관에 영향을 준다는 점에서, 가방의 외주의 형상과의 위치관계를 고려하면 장식 단추의 수나 배치의 차이점은 양 의장에 다른 미감을 주는 것으로 판단하여, 양 의장의 동일성을 부정하여 신규성상실의 예외의 적용을 배제하고, 원고의 청구를 기각하였다.[88]

전술한 바와 같이 일본은 최근 법개정을 통해 절차적 요건을 완화하면서, '동일 또는 유사한 디자인'에 대해서 2이상의 복수의 공지가 있는 경우 최선의 일에 행해진 것에 대해서만 증명서를 제출하면 되도록 하여, 유사한 의장에 대해서도 인정될 수 있는 것으로 되어 있는바, 향후 그 적용범위는 다소 확대될 것으로 기대할 수도

87) 해당 사건에서는 모자의 퍼가 착탈 가능한 코트의 경우, 퍼를 뺀 상태와 퍼를 붙인 상태가 실질적으로 동일하지 않다고 판단하였는데, 동적 의장의 변화를 고려하여 물품의 기능이나 성질 등에 비추어 동일한 범위 내에 있는 것이라 볼 수 없다고 판단한 것이다.

88) 意匠法4条2項の新規性喪失の例外と公開意匠の証明書記載の意匠と引用意匠の同一性に関する「バッグ」事件知財高裁判決について, innoventier power for the Business, 2024, https://innoventier.com/archives/2024/01/16292 , 최종 검색일: 2024. 09. 20.
심사단계에서는 증명서에 기재된 의장과 인용의장은 금소제의 수나 배치, 본체부와 손잡이의 색채가 다르다는 점에서 동일성이 결여된다고 판다하여 거절결정을 하였고, 거절결정불복심판에서도 심사와 같은 판단이 내려졌다. 이에 원고는 심결취소소송을 제기하였고, 판결에서는 의장법4조3항의 취지에 비추어 증명서에 기재된 의장과 인용의장은 동일할 것을 요한다고 판시하였다. 한편, 판결에서는 '동일'의 의미에 관하여, 양자가 차이점이 있다 하더라도 실질적으로 동일한 경우, 즉, '물품의 성질이나 기능에 비추어 실질적으로 동일하다고 충분히 이해할 수 있는 범위 내의 것이라 인정되는 경우'에는 동일한 것으로 인정할 수 있다고 판시하였다. 근소한 차이점에 불과한 경우에도 동일성을 인정하지 않는 것은 바람직하지 않으며, 출원인의 절차적 부담을 고려하더라도 증명서에 기재된 의장과 인용의장의 차이점이 물품의 성질이나 기능에 비추어 실질적으로 동일하다고 충분히 이해할 수 있는 범위 내의 것이라 인정되는 경우에는 동일한 것으로 인정할 수 있다는 것이다.

있을 것이나, 위의 단자반 사건에서는 유사한 범위까지 인정되는 것으로 해석하고 있음에도 불구하고 최근의 판결예에서는 그 범위를 매우 한정적으로 해석하고 있다는 점에서, 그 구체적 판단은 사안에 따라 달라질 수 있을 것으로 생각된다.

한편, 東京高判 平成12. 11. 28. 平12(行ケ)331 강판 사건에서는 디자인공보 등에 게재된 경우와 관련하여, "국내외에서 디자인의 등록출원을 한 결과, 디자인공보 등에 게재되었다는 것은 그 출원 시점에서 이미 출원의 준비가 완료된 것이라 말할 수 있기 때문에, 이러한 경우에 신규성을 상실한 것으로 취급해도 출원인에게 가혹하다고 할 수 없으며, 조약에 따른 우선권 주장이 가능하도록 규정되어 있는 바, 이를 구제할 필요성은 인정되지 않는다."라고 판시하였는데,[89] 2011년 일부 개정에서 의장 등록을 받을 권리를 가진 자의 내외국 특허청에서의 출원행위에 기인하여 특허공보 등에 게재함으로써 신규성을 상실한 경우에는 신규성 상실의 예외의 대상이 되지 않는다고 해석하고, 운용해 왔던 것을 명문화하였다.[90] 외국에서의 출원의 경우, 파리조약이 적용되어 출원일로부터 6개월 동안은 해당 의장의 공표를 근거로 불이익을 받지 않기 때문에, 이러한 기간을 도과한 자에게 의장법 제4조 제2항을 적용하여 그 후에도 일정한 기간 동안 신규성을 상실하지 않은 것으로 하여 보호를 하는 것은 파리 조약의 취지에도 반하며, 권리자에게 과분한 이익을 부여하는 것이 되고, 나아가 상기 기간이 도과한 것을 믿고 행동한 제3자에게 불측의 손해를 가져올 우려가 있다고 그 이유를 설시하였다. 東京高判 昭42·11·21判タ215号184頁 사건에서는, 외국에서의 출원공개가 '의사에 반한 공지'에 해당하는지 여부가 쟁점(프랑스특허명세서가 출원인의 예상보다 빨리 발행되어 신규성을 상실한 것은 출원인의 의사에 반한 것이라고 주장한 사안)이 되었는데, 법원은 "출원인이 본원 발명을 자유로운 의사에 근거하여 프랑스 특허청에 출원한 이상 이후의 프랑스특허명세서가 언제 공지되는지 여부는 출원인의 의사와 전혀 상관없는 것이고, 출원인이 공지를 희망하는지 여부와 상관없이 결정되는 일이기 때문에, 의

89) 해당 사건에서는 내외국에서 의장의 등록출원을 한 결과, 의장 공보 등에 게재되었다는 것은 그 출원 시점에서 이미 출원의 준비가 완료한 것이라 할 수 있기 때문에, 그런 경우에 신규성을 상실한 것으로 취급하더라도 의장의 고안자에게 가혹하다 할 수 없으며, 의장법 4조 2항에 의해 이를 구제하는 실질적인 필요성은 인정되지 않는다.

90) 特許庁 総務部 総務課 制度審議室 編集,『逐条解説〔第22版〕意匠法』, 一般社団法人発明推進協会, 2022, 1261면.

사에 반했는지 여부가 문제가 될 여지는 전혀 없는 것"이라 판시하였다.

(나) 미국

미국특허법(United States Code Title 35) 제102조는 등록요건으로서 신규성에 관해 규정하고 있는데, 제102조(a)항에서는 신규성의 기본 원칙을, 제102조(b)항은 (a)항에 대한 예외를 규정하고 있다.[91] 공지예외 규정은 제102조(b)항으로, 제102조(b)(1)(B)의 규정에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 공개가 발명자의 공개와 특허출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 공개보다 빠르면 제3자의 공개는 선행기술이 되지 않으며, 제102조(b)(2)(B)에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 출원이 발명자의 공개와 출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 출원보다 빠르기만 하면 제3자의 출원은 선행기술이 되지 않는다.[92][93] 즉, 제102조 (b)(1)은 Grace Period를 규정하고 있는 것이고, 제102조 (b)(2)는 이른바 모인출원 등과 같이, 본원의 과제가 개시된 출원이 제3자에 의해 이루어진 경우에 본원은 이러한 모인출원에 의해 거절되지 않는 것을 도모하기 위한 규정으로 이해된다.

(다) 유럽

유럽 공동체디자인 규정 제7조 제2항은 디자이너, 그의 승계인, 또는 제3자가

---

91) 미국특허법 §102 특허 등록요건; 신규성
(b) 예외
(1) 청구된 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 개시 - 다음에 해당하면 청구된 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 개시는 그 청구된 발명에 대하여 제102조(a)항(1)호에 따른 선행기술을 구성하지 않는다.
(A) 그 개시가 그 발명자나 공동발명자, 또는 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 이루어진 경우; 또는
(B) 개시된 주제가, 그 개시 전에, 그 발명자나 공동발명자, 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우
(2) 출원서나 특허에 기재된 개시 - 다음에 해당하면 그 개시는 그 청구된 발명에 대하여 제102조(a)항(2)호에 따른 선행기술을 구성하지 않는다.
(A) 개시된 주제가 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 득한 경우;
(B) 개시된 주제가, 그러한 주제가 제102조(a)항(2)호에 따라 유효하게 출원되기 전에, 발명자 또는 공동발명자 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우

92) 홍정표, 앞의 글(주 66), 45면.

93) 이런 의미에서 미국은 '선원주의'가 아닌, '선개시(先開示)주의'라 설명되기도 한다.

디자이너나 그의 승계인의 정보 제공이나 조치로 인해 디자인이 대중에게 공지되더라도, 출원일 또는 우선일 전 12개월 이내에 해당하는 경우에는 해당 공지는 제5조(신규성) 및 제6조(독자성)를 적용함에 있어서 고려하지 않는다는, 이른바 공지예외에 관한 사항을 규정하고 있다. 제5조(신규성)에서는 공중이 이용할 수 있는 디자인과 동일하지 않은 경우 신규한 것으로 간주한다고 규정하고 있는데, 중요하지 않은 부분에서 차이가 있는 경우에도 동일한 범주 내에 포함하는 것으로 명시하고 있다. 또한, 제7조 제3항에는 디자인이 디자이너나 그의 승계인에 대한 부당한 행위의 결과로 대중에게 공지된 경우에도 적용되는 것임을 명시하고 있다.

(3) 개선점

(가) 제3자에 의해 디자인이 공지된 경우의 취급

우리나라 디자인보호법에는 출원인의 출원 전 공개디자인을 모방한 제3자의 공개에 대하여 아무런 규정이 없다. 따라서 제3자 공지의 경우, 법 해석에 의해서 신규성 상실의 예외 규정의 적용 여부를 판단해야 하는데, 가령, 디자인의 창작자가 공개한 것에 기인하여 타인이 공개한 경우에는 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것으로 보고 있고,[94] 또한, 제3자에 의한 공개가 창작자의 최초 공개에 근거한 것일 경우에는 2회차 공개부터는 여러 번의 공개 행위가 있는 경우와 마찬가지로 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것으로 보는 견해가 있다.[95]

반면, 앞서 살핀 바와 같이, 미국 특허법에서 공지예외 규정은 제102조(b)로, 제102조(b)(1)(B)의 규정에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 공개가 발명자의 공개와 특허출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 공개보다 빠르면 제3자의 공개는 선행기술이 되지 않으며, 제102조(b)(2)(B)에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 출원이 발명자의 공개와 출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 출원보다 빠르기만 하면 제3자의 출원은 선출원 또는 선행기술이 되지 않는다는 점을 명확히 하고 있다.

---

94) 노태정·김병진, 『디자인보호법』, 세창출판사, 2009면, 255면.
95) 정태호, 앞의 글(주 5), 127면.

또한, 유럽공동체 디자인의 경우에도, 제7조 제2항에서 디자이너를 모방한 제3자의 공지, 제7조 제3항의 '부당한 행위'의 해석에 의해, 제3자의 모방 디자인에 의한 공지 및 제3자의 의사에 반한 공지에까지 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있음을 명확하게 규정하고 있다. 특히, 부당한 행위에 따른 의사에 반한 공지의 경우, 자기 공지와는 달리 별도로 12개월 이내에 출원해야 한다는 기간요건을 두지 않는다. 의사에 반한 공지인 경우, 출원인이 공지여부를 확인할 길이 없는 경우도 있을 수 있고 원래부터 출원의사가 없을 수도 있는 것이므로, 굳이 12개월 내 출원요건을 부과할 필요는 없어 보인다.

한편, 타인의 공개가 제3자의 독창적인 창작에 기하여 이루어진 경우에는 본 규정의 적용을 받을 수 없게 된다는 점에 대해서는 이론의 여지가 없을 것이나,[96] 제3자가 디자이너의 공지디자인을 근거로 삼아 그것에 창작적 요소를 가하여 변형함으로써 공개한 경우에 신규성 상실의 예외 규정이 적용가능한지 여부에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 가령, 창작자가 A 디자인을 공지한 이후, A에 근거하여 ①제3자가 A와 유사한 A1을 창작하여 공지한 경우, ②제3자가 A와는 유사하지 않은 A2를 창작하여 공지한 경우,[97] ③제3자가 A와는 유사하지 않으며 A로부터 창작이 용이하지 않은 A3을 창작하여 공지한 경우, 이러한 제3자의 A1, A2 및 A3에 대해서도 신규성 상실의 예외 주장이 가능한지 여부에 대해서는 명확하지 않다. 지금까지의 법 개정이 '창작자의 독점실시디자인 영역'으로 인정하기 위해 지원하는 제도로서, 창작자 자신의 공지디자인에 대한 디자인권 확보라는 취지를 더욱 강화하는 방향으로 흘러왔다는 점을 고려하면, ①의 경우, A1은 창작자의 디자인 A의 독점실시디자인의 영역에 있는 것이므로 A1에 대해서는 신규성 상실의 예외 주장을 인정한다고 볼 수도 있을 것이다.[98]

96) 노태정·김병진, 앞의 글(주 94), 255면.

97) 용이창작이 가능한 정도의 것에 한정한다.

98) 다만, 특허심판원의 판단이기는 하나, 2019당4003 심결에서는 '출원인의 최초 자기실시디자인의 공지일과 출원일 사이에 제3자인 타인의 실시디자인이 공지된 경우, 그 12월 내 출원이라도 그 타인의 중간공지가 출원인의 창작디자인과 동일하지 않고 이를 단순 모방, 복제한 것에 불과하지 않은 독자적인 창작에 기인한 경우에는 신규성의제규정의 적용을 받을 수 없고, 공개된 타인의 창작디자인에 의해 신규성이 상실되어 디자인등록을 받지 못한다. 즉 타인의 중간공지가 신규성의제에 인정되는 피청구인의 실시디자인과 동일성이 있다면 모인출원으로 신규성 상실의 예외 적용을 받을 수 있으나, 양 디자인이 유사한 정도에 그친다면 이에 의해 출원(등록)디자인은 신규성이 상실된다고 보아야 할 것이다.'라고 판단하였다.

하지만, ②와 ③의 경우, A2는 창작자의 독점적 실시 디자인의 영역을 넘는 범위에 있는 것으로, 이러한 범위까지 신규성 상실의 예외 규정을 인정하게 되면, 디자인권자의 실질적인 창작의 기여가 있는 범위를 넘어서는 범위까지 창작자의 권리로서 인정되는 결과를 초래하게 될 우려가 있다. 특히 ②, ③의 경우, 대상 판결에 따르면 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변이 인정되지 않는 점을 고려하면, A2와 A3에 대해서 신규성 상실의 예외가 인정되게 되면 A2, A3을 근거로 하여 자유실시디자인의 항변이 불가능하게 되어 제3자의 이익을 지나치게 제한하는 결과를 초래할 우려가 있다.

제3자의 모방의 경우, 위의 ①에 케이스에 해당하는 경우가 적지 않다는 점에서, 이러한 부분에 대해서는 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다 볼 수도 있으나, 위의 ②와 ③의 경우에 관해서는 제3자와의 형평을 고려하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 제한하는 것이 바람직한 것으로 이해되는바, 이러한 부분에 대한 예측 가능성을 높이기 위해서도 제3자에 의한 공지에 관한 명확한 규정을 마련하는 것이 바람직한 것으로 이해된다.[99][100]

(나) 출원디자인과의 관계에서 공지디자인의 범위

현행 디자인보호법에서는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대하여 어떠한 제한을 두고 있지 않아, 양 디자인이 동일 또는 유사한지 여부에 상관없이 출원디자인이 소정의 요건만 충족하면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것으로 보는 견해도 있다.[101] 이러한 견해에 따르면, 공지디자인과 출원디

99) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244-245면.
특허의 경우에도 같은 논리가 적용되어, 특허를 받을 권리를 가진 자의 발명에 개량 등을 가해 공개한 경우, 해당 타인에 의해 개량 등이 된 발명은 본 규정의 '특허를 받을 권리를 가진 자의 행위에 기인하여 제29조 제1항 각호의 어느 것에 해당하기에 이른 발명'에는 해당하지 않아 본항의 규정을 적용받을 수 없다고 본다[特許庁 総務部 総務課 制度審議室 編集, 앞의 글(주 90), 99면].

100) 일본의 경우 타인의 공개한 출원 디자인과 유사한 공지디자인에 대해서는 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 없다는 것이 통설인데, 그 구체적인 내용에 관해서는 후술하는 관련디자인 제도와의 관계에서 신규성 상실 예외 규정의 일본의 운용 참조.

101) 공경식·이승훈, 『코어디자인보호법(제12판)』, 한빛지적소유권센터, 2015, 149면[김기수, 앞의 글(주 1), 108면 재인용]

자인 사이에 동일·유사 여부를 판단하지 않는 이유는, 만약 출원디자인과 동일·유사한 공지디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외가 적용된다고 한다면, 양 디자인이 비유사한 경우에는 그 공지디자인에 대하여 신규성 상실의 예외가 인정되지 않을 뿐만 아니라, 출원디자인은 그 공지디자인에 의해 용이창작으로 거절될 수 있기 때문이라고 본다.

그러나, 위와 같은 견해는 디자인 창작자의 관점에서만 바라본다면 일견 타당해 보일 수도 있지만, 대상판결이 "신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것"이라고 판시했는바, 제3자의 관점에서 보면 공지디자인을 박탈하는 결과를 초래하게 되는 불합리가 발생한다.

앞서 주요국의 운용에서 살핀 바와 같이, 일본에서는 출원디자인과 동일 또는 유사한 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 것으로 운용하고 있고, 유럽 공동체 디자인규정에는 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받기 위한 절차적 규정을 두고 있지는 않으나, 제5조 제2항에서 디자인의 특징이 중요하지 않은 세부 사항만 다른 경우도 동일한 것으로 간주하여 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있음을 규정하고 있다. 이처럼 주요국에서는 신규성 상실의 예외 규정이 적용될 수 있는 공지디자인의 범위에 대해서 제한을 두고 있다는 점에서, 우리나라와는 상당히 다르게 운용되고 있음에 유의할 필요가 있을 것이다. 전술한 제3자에 의해 디자인이 공지된 경우의 취급에서도 살펴보았듯이, 유사 범위를 넘어선 부분에 대해서 신규성 상실의 예외가 인정되게 되면, 제3자의 개량이 추가된 범위에 관해서도 인정될지 여부에 대한 추가적인 해석이 필요하게 되는바, 대상판결에서 판시한 바와 같이 제3자와의 이익균형을 도모하기 위해서도, 주요국에서와 같이 적용 범위를 유사 범위로 명확히 할 필요가 있다고 생각된다.

또한, 우리나라의 경우 일본과 달리 법문상 명문의 규정은 없지만, 대법원 판례에 따라,[102] 여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도, 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면, 공지된

102) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결.

나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 보고 있다. 그러나 최근 절차적 요건 규정의 삭제로 인하여, 위와 같은 논리 구성은 더 이상 의미가 없게 되었고, 앞으로는 여러 번의 공개행위에 따른 각각의 공지디자인과 출원디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는지를 살피는 구조로 바뀌게 되었다고 할 수 있다.

다 관련디자인 제도와의 관계에서 신규성 상실의 예외 규정

(1) 문제의 소재

우리 디자인보호법 제36조 제1항에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니하는 것으로 보는 한편, 법 제35조 제1항은 '디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 "기본디자인"이라 한다)과만 유사한 디자인(이하 "관련디자인"이라 한다)에 대하여는 그 기본디자인의 디자인등록출원일부터 3년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 제33조제1항 각 호 및 제46조제1항 · 제2항에도 불구하고 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다'라고만 규정되어 있다.[103]

자기의 디자인과의 관계에서는 그 디자인이 기본디자인과 유사한 자기의 선행디자인에 유사한 것을 이유로 거절되지 않는다는 견해도 있으나,[104] 현행 디자인보호법에서는 명문의 규정이 존재하지 아니하고, 심사기준에도 "관련디자인등록출원은 기본디자인등록출원일과 관련디자인등록출원일 사이에 공지된 자기의 기본디자인과 동일 또는 유사한 디자인으로 인해 거절되지 않는다."라고만 설명되어 있어,[105] 기본디자인의 출원일 이전에 공지된 자기의 디자인 또는 이와 유사한 디자

103) 관련디자인은 기본디자인과의 관계에서 신규성 또는 선출원 규정의 예외를 인정하는 것일 뿐이고, 이를 제외한 나머지 등록요건은 일반적인 디자인등록요건과 같은데, 관련디자인으로 등록되기 위해서는 기본디자인을 제외한 선행공지디자인과의 관계에서 디자인으로의 일반적 요건(공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성, 확대된 선출원 등)이 모두 구비되어야 한다[윤태식, 앞의 글(주 14), 407면].

104) 정상조 외 3인 공편, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015, 338면[손천우 집필부분].

인에 대해 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는지 여부는 명확하지 않다. 관련디자인으로 등록받을 수 있는 기간이 3년으로 연장됨에 따라, 관련디자인등록출원이 자기의 디자인 또는 이와 유사한 디자인이 공지된 이후 1년이 경과된 후에 출원 가능해짐에 따라, 이러한 공지디자인들에 대한 신규성 상실의 예외 주장이 가능한지 여부가 중요해질 수밖에 없는데, 이하에서는 우리와 유사한 제도를 운용하고 있는 일본에서의 운용을 검토한 이후 국내의 바람직한 운용에 대해 검토해 보고자 한다.

(2) 일본의 운용

일본은 일반적인 신규성 상실 예외 규정(의장법 제4조)과는 별도로, 관련의장제도(의장법 제10조)에 대해서도 신규성 상실의 예외 규정을 추가로 마련하고 있는데, 의장법 제10조 제2항 및 제8항이 그것이다.[106] 관련의장의 출원 시에는 기본의장의 '등록의장공보'나 '자기 실시에 의한 공지의장'이 존재하게 되는데, 이러한 '등록의장공보'나 '공지의장'을 인용 예로 취급하지 않을 것을 명확히 규정하고 있는 것이다.

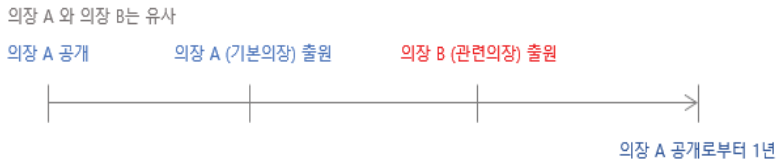
의장법 제4조의 신규성 상실의 예외 규정의 적용은 출원별로 절차를 행할 필요가 있는데, 가령 아래의 그림 1의 시계열로 공개행위와 출원행위가 이루어진 경우, 디자인 A의 출원시에 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받기 위한 절차를 진행하였다 하더라도 디자인 B의 출원시에 해당 절차를 진행하지 않게 되면, 디자인 B는 공지디자인 A의 존재에 의해 디자인등록을 받을 수 없게 된다.[107] 이러한

105) 특허청 편, "디자인보호법 심사기준", 특허청, 2023, 129면.
다만, 디자인보호법 제35조 제1항의 규정는 '자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인과만 유사한 디자인'이라고 규정되어 있는바, 기본디자인등록출원일과 관련디자인등록출원일 사이에 공지된 자기의 기본디자인과 동일 또는 유사한 디자인으로 인해 거절되지 않는 것으로 확대 해석 가능할지는 의문이다.

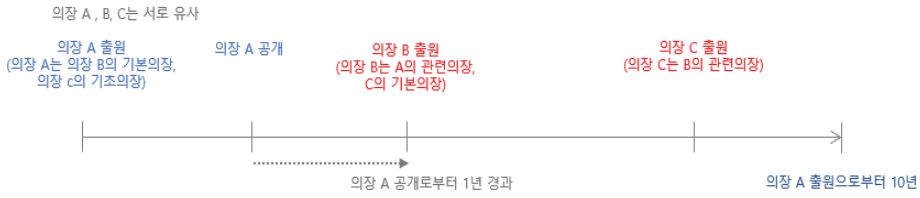
106) 의장법 10조 2항 '제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 자기의 의장 중 전항의 규정에 의하여 의장등록을 받고자 하는 의장의 본의장과 동일 또는 유사한 것은, 해당 의장등록을 받고자 하는 의장에 관하여 동조 제1항 및 제2항의 규정의 적용에 대해서는, 동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 것으로 본다.'라고 규정되어 있다. 아울러, 연쇄적인 관련의장에 관해서 이러한 취지를 규정한 것이 제10조 제8항으로, 제10조 8항은 관련의장과만 유사한 경우에도 관련의장으로 등록을 받도록 개정되면서 추가로 규정되었다.

107) 小谷悦司 외 2인 編集,『意匠·デザインの法律相談I (第35巻)(最新青林法律相談 35)』, 青林書院 2021, 275면.

것이 원칙이나, 일본의 관련의장제도는 기초의장의 출원일로부터 10년이라는 장기간에 걸쳐 이루어질 가능성이 있기 때문에, 그 사이에 기초의장 및 기초의장에 관한 관련의장이 제품의 판매 등에 의해 공개되는 것은 당연한 것이고,[108] 이러한 경우에도 관련의장이 등록을 받을 수 있도록 하기 위해서, 제10조 제2항·제8항의 규정을 둔 것이다. 즉, 의장법 제10조 제2항·제8항에 의해, 가령 그림 2와 같이 의장 B 및 C의 관련의장출원 시에 의장법 제4조의 신규성 상실의 예외 규정의 적용 절차를 행하지 않았다 하더라도, 신규성 상실의 예외와 같은 효과가 자동적으로 부여되며, 공개 후 1년 내에 출원하지 않으면 안 된다고 하는 시기적 제한도 없게 되는 것이다.[109]



〈그림 1〉



〈그림 2〉

다만, 공지가 된 '자기 실시에 의한 공지의장(이하 '자기의 의장'이라 한다)'의 해석에 있어서, 선원인 기본의장의 의장등록공보에 게재된 의장이나 기본의장에 관한 자기 실시 의장이 포함되는 것을 전제로, 그 외에 어떠한 것이 포함되는 것인지는 명확하지 않다는 지적이 있다.[110] 이에 대해서는, 의장권 취득 후 제3자에게

108) 일본의 관련의장제도의 경우, 관련의장에만 유사한 경우에도 관련의장으로 등록을 받을 수 있는데, 기본의장 중에 최초로 선택된 것을 기초의장이라 하고(즉, 기본의장으로서 다른 의장의 관련의장이 아닌 것), 기본의장은 관련의장으로 출원하면서 해당 관련의장과 유사한 의장으로서 지정한 의장을 의미한다.

109) 小谷悦司 외 2인 編集, 앞의 글(주 111), 276면.

110) 青木大也, 앞의 글(주 64), 241면.

라이센스를 제공하여 실시하게 한 결과 공지가 되었다면 자기 실시의 경우와 같이 공지가 된 '자기의 의장'으로 정리하는 것이 적절하며, 또한, 타인인 디자이너가 창작한 의장에 관해서, 공지가 되기 전에 그 의장등록을 받을 권리나 의장권을 취득하고, 이를 활용하여 일연의 의장 그룹을 전개해 가는 것도 생각할 수 있기 때문에, 권리양도 등에서 타인의 권리를 취득한 경우에도 '자기의 의장'으로 보는 것이 바람직하다는 의견이 제시된다.[111]

한편, 타인이 어떠한 창작적 노력을 부가하지 않은 모방품을 제작, 판매하여 공지한 경우, 그 모방품도 자기의 의장에 해당하는 것으로 보는 반면,[112] 타인이 '자기의 의장'에 의거하여 그와 유사한 의장을 공지한 경우에는 해당 유사한 의장에 관해서는 '자기의 의장'으로서 신규성 상실의 예외의 적용을 받을 수 없다고 본다.[113] 조문의 문언상 '자기의 의장'에 유사한 의장이라 기재되어 있지 않으며, 실질적으로도 '자기의 의장'에 유사하다고 하더라도 타인의 창작이 개입된 결과 다른 의장이 되었다고 생각할 수 있으며, 제3자에게 영향을 주지 않는다고 하는 입법의 취지에서 보더라도 이를 그대로 관련의장으로서 권리화하는 것을 허용하는 해석은 해서는 안 되기 때문이다.[114] 다만, 실질적으로 자기의 의장에 타인의 의장이 더해져 공지가 된 경우, 의장의 동일 또는 유사의 차이 등을 구별하기는 쉽지 않을 것이라는 지적이 있다.[115]

즉, 조문에서는 '자기의 의장'으로만 규정하고 있는데, 자기가 창작한 것이나 의장등록출원을 한 것, 자기가 공지한 것, 자기가 실시한 것 등이 요건으로 되어 있지 않음에 유의할 필요가 있다.

111) 青木大也, 앞의 글(주 64), 241면.

112) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244면.
다만, 이러한 모방품에는 타인이 어떠한 창작적 노력을 부가하지 않은 것을 의미하는 것으로 이해된다.

113) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244-245면.
가령, 자동차에 관한 의장이 존재하고, 이를 기초로 하여 타인이 범퍼를 추가하거나, 타이어를 교환하거나 하여 공지한 의장이 존재하는 경우, 해당 타인의 자동차 의장이 전체로서 '자기의 의장'과 유사한 의장이라고 정리를 하게 되면, 해당 타인의 자동차 의장에 관하여 신규성상실의 예외의 적용을 받을 수 없다고도 볼 수 있는데, 이렇게 되면 관련의장제도의 개정의 취지를 살릴 수 없다는 점에서 자기의 창작에 관한 의장이 구별되어 인식되는 경우에는 해당 부분에 관해서는 자기의 의장으로 해석하여 신규성 상실의 예외의 적용을 긍정하는 것이 바람직하다는 견해이다.

114) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244면.

115) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244면.

아울러, 의장법 10조에서 공지가 된 의장에 신규성 상실의 예외 효과가 부여되는 것은 그것이 자기의 기초의장 또는 기초의장에 관한 관련의장과 동일 또는 유사한 경우에만 한정되는 것이기 때문에, 공개한 의장이 기본의장(또는 기초의장)과 비유사한 경우에는 의장법 10조의 규정에 따른 신규성 상실의 예외의 효과를 적용받을 수 없게 된다.[116]

(3) 개선점

현행 디자인보호법 상 관련디자인 규정에는 출원 또는 등록된 기본디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외가 규정되어 있을 뿐, 그 외에 공지된 자기 디자인과의 관계에 대해서는 아무런 규정이 없다. 물론, 관련디자인 출원 전 1년 이내에 공지된 자기 디자인의 경우에는 디자인보호법 제36조에서 규정하는 신규성 상실의 예외를 적용할 수 있게 되지만, 관련디자인으로 등록 가능한 기간이 3년으로 연장된 현재로서는 공지일로부터 1년이 경과된 공지디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외를 적용할 수 있을지는 명확하지 않다.

관련디자인 제도는 제35조 제1항의 규정상 그 자체로 기본디자인과의 관계에서 '신규성 상실의 예외로서'의 측면이 있는 것이라는 점에서, 당연히 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 공지디자인에 의해 거절이 되어서는 안 된다고도 볼 수 있으나, 현행 규정으로서는 기본디자인이 출원되기 전에 공지된 디자인들에 의해 관련디자인들이 거절될 가능성은 충분히 존재하는 점에서, 디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외 규정과의 정합성이 맞도록 개선될 필요가 있을 것이다. 다만, 기본디자인의 출원 전 공지된 디자인들에 의해 거절되지 않도록 하는 등의 규정을 새롭게 추가하게 되면, 가령, 자기의 디자인 A를 공지한 이후 12개월 이내에 A'을 출원하고, A' 출원일부터 3년 이내 A'과 유사한 디자인 A를 관련디자인으로 출원한 경우, A가 공지된 이후 4년 정도 경과된 시점에 이르러 디자인 A가 등록이 가능한 경우도 생긴다는 점에서, 신규성상실예외규정의 시기적 제한을 실질적으로 잠탈할 우려가 있고, 관련디자인으로서의 출원 가능한 기간은 실질적으로 1년이

116) 小谷悅司 외 2인 編集, 앞의 글(주 111), 277면.
다만, 이 경우에도 관련의장의 출원 시기가 비유사한 의장의 공개로부터 1년 이내로 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있도록 절차를 진행한 경우에는 등록을 받을 수 있다.

연장된다고도 보는 우려가 있을 수도 있다.[117]

그럼에도 불구하고, 이러한 부분들에 대한 구제가 이루어지지 않게 되면, 최근 디자인보호법 제36조의 신규성상실예외 규정에서 기본적인 절차적 요건을 폐지하고 널리 신규성 상실 예외를 인정하자는 취지와 상충될 것이다.[118] 또한, 일본의 경우 관련 의장으로 등록 가능한 기간이 10년으로 연장되었음에도 불구하고, 이러한 관련 의장에 대해서도 의장법 제10조 제2항 및 제8항에 신규성 상실의 예외 규정을 마련하고 있는 점도 참고할 필요가 있다.

따라서, 관련디자인 규정에 신규성 상실 예외 규정을 추가함으로써 관련디자인과 신규성 상실 예외 규정의 관계에 대한 규정을 통해서, 자기의 디자인과의 관계에서는 그 디자인이 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 선행디자인을 근거로 거절되지 않음을 명확히 하는 것이 바람직해 보인다.

5 자유실시디자인의 항변에 대한 검토

가 문제의 소재

최근 5년간(2019년 이후부터 2024. 9. 11.까지) 특허법원에서 155건의 권리범위확인심판의 취소를 구하는 판결들이 선고되었는데, 이들 판결들을 분석한 결과, 155건 중 자유실시디자인의 항변에서 용이창작 여부를 실제로 판단한 건들은 30건이었으며, 그 중 20건에 대해 용이창작에 의한 자유실시디자인의 항변이 인정되었다.

117) 青木大也, 앞의 글(주 64), 247면.
동일한 상황이 일본 의장법 개정에 의해서도 발생할 우려가 제기되고 있다. 특히 일본의 경우 관련의장으로 등록 가능한 기간이 10년이라는 점에서, 최초 공지된 시점에서 10년이 경과된 경우에도 등록이 가능하다 할 수도 있을 것이다.

118) 青木大也, 앞의 글(주 64), 235면.
한편, 관련의장제도의 경우 대기업 등이 이용하는 경우가 많기 때문에, 신규성상실예외주장과 관련하여 실질적인 이용이 많은 개인 출원인들의 편의를 위해서 신규성상실예외 주장의 절차를 간소화하는 것이 바람직하다는 견해도 제시된다.

우리의 실무는 디자인권의 창작비용이성 판단에서 인용될 수 있는 선행디자인의 범위를 매우 넓은 범위에서 허용하는 경향이 있다.[119] 실제 최근 5년간 특허법원에서 선고된 판결례를 분석해 보면, 그러한 경향을 엿볼 수 있는데, 용이창작을 이유로 등록이 무효된 비율은 47.36%에 이르고, 용이창작을 이유로 자유실시디자인의 항변이 인정된 비율도 66.66%에 이르고 있음을 알 수 있다.[120] 일부 사건에서는 확인대상디자인과 선행디자인과의 차이점들에 대해, 그 일부는 선행디자인들에 공지되어 있고, 나머지 부분들은 공지된 형태들에 해당한다는 논거를 사용하여 용이창작이 가능하다고 판단하였다. 결국, 이러한 공지된 형태들도 복수의 선행디자인들에 개시된 것으로, 실질적으로 4개 이상의 선행디자인들의 결합에 의해 용이창작이 가능하다고 판단한 것으로 볼 수 있다는 점에서, 판결례에서 제시하고 있는

119) 가령, 미국의 경우, 디자인특허의 자명성 판단에서 오랜 기간 Rosen-During 테스트가 사용되어 왔는데, Rosen-During 테스트에서는 스텝 1에서 기본적으로 동일한 디자인 특징을 가지는 주선행디자인(primary reference)을 제시하고, 스텝 2에서에서는 그러한 주선행디자인이 제시된 경우, 주선행디자인과 관련이 있는 부선행디자인(secondary reference)을 근거로, 주선행디자인을 변경하여 클레임 디자인을 창작하는 것이 당업자에게 있어서 자명한지를 판단하게 된다. 하지만, 이러한 판단법리에 따르면, 주선행디자인으로 인정되는 것조차 어렵기 때문에, 디자인의 자명성 판단에서 사용되고 있는 Rosen-Durling 테스트를 부정하거나 변경해야 한다는 주장이 제기되어 왔다[Sarah Burstein, "IS DESIGN PATENT EXAMINATION TOO LAX?", 『BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 』, Vol. 33(2018). 616-617면]. 2024년 5월 21일 CAFC 전원법정 판결에서는 오랜 기간 기준으로 여겨졌던 전술한 2단계 테스트가 부적절하고 엄격하여, 2007년 연방대법원의 특허발명의 진보성 판단기준에 관한 KSR 기준을 따르지 않는 점이 지적되었다. 즉, 디자인특허도 특허발명과 같이 유연한 판단 방법을 채용해야 한다고 설시함에 따라 보다 넓은 범위의 선행디자인을 제시할 수 있게 되었으며, 복수의 선행디자인을 결합하는 동기부여도, 선행디자인 자체만이 아니라, 당업자의 상식이나 설계상의 수요 등 다양한 관점에서 평가 가능하게 되었다[LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 사건]. 우리의 경우, 물품 분야가 다르더라도 선행디자인으로 인용될 수 있으며, 미국 항소법원에서 요구하는 주된 자료 및 보조 자료와 같은 정도의 엄격한 요건을 요구하지도 않으며, 인용될 수 있는 선행디자인의 수에도 제한이 없다[안원모, "미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰", 『지식재산연구』, 제11권 제2호(2016), 144면].

120) 2019년 이후 2024. 9. 11. 현재까지 특허법원에서 185건의 등록무효심결의 취소를 구하는 판결이 선고되었고, 그 중에서 용이창작 여부를 실제로 판단한 건들은 50건이었으며, 그 중 용이창작에 의한 등록무효가 인정된 건들은 27건에 이르렀다. 또한, 같은 기간 동안 155건의 권리범위확인심판의 취소를 구하는 판결이 선고되었고, 그 중에서 자유실시디자인의 항변에서 용이창작 여부를 실제로 판단한 건들은 30건이었으며, 그 중 20건에 대해 용이창작에 의한 자유실시디자인의 항변이 인정되었다. 한편, 해당 판단에서 판단의 근거가 된 선행디자인의 수는 아래의 표와 같다.

선행디자인의 수	1	2	3	4이상	합계
용이창작에 의한 등록무효	11(40.7%)	11(40.7%)	3(11.1%)	2(7.4%)	27(100%)
용이창작에 의한 자유실시디자인 인정	12(60.0%%)	3(15.0%)	2(10.0%)	3(15.0%)	20(100%)
합계(%)	23(48.9%)	14(29.8%)	5(10.6%)	5(10.6%)	47(100%)

자유실시디자인의 항변에서의 용이창작의 판단기준의 '쉽게 실시할 수 있는 디자인'에 해당한다고 단언할 수 있는지는 의문이다.

한편, 권리범위확인심판이나 침해소송 등에서 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를 판단하는 '자유실시디자인 항변의 판단'에서 '디자인의 유사여부'의 판단기준은, '공지디자인의 항변이나 권리남용 항변'에서의 '등록디자인의 무효여부에 대한 판단', '확인대상디자인(실시제품)이 등록디자인의 권리범위에 속하는지에 대한 판단'에서의 '디자인의 유사여부'의 판단기준과 정합성을 가져야 할 것이다. 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결에서는 원심의 판결이유와 관련하여, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인, 확인대상디자인과 비교대상디자인, 등록디자인과 확인대상디자인의 각각의 유사여부 판단에서 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사여부를 판단하였다는 점에서 논리의 일관성이 없음이 지적되기도 하였다.[121]

디자인의 유사여부 판단에서 공지부분을 포함하는 경우, 등록요건을 판단하는 단계와 침해여부를 판단하는 단계에서 그 기준이 달리 적용되고 있는데,[122] 신규성과 같이 등록요건을 판단하는 장면에서는 공지된 부분이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이를 포함하여 판단하도록 하는 반면,

121) 원심(특허법원 2016. 5. 13. 선고 2015허8240 판결)에서는 확인대상디자인과 비교대상디자인의 유사여부 판단에서 양 디자인의 공통점들은 대상물품인 앵글밸브의 기능을 확보하기 위하여 기본적으로 갖추어야 할 형상이므로 유사여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여, 양 디자인의 차이점들이 지배적인 특징에 해당하며 이러한 차이점들로 인하여 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 유사여부 판단에서도 양 디자인의 공통점들은 대상물품인 앵글밸브의 기능을 확보하기 위하여 기본적으로 갖추어야 할 형상이므로 유사여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여 양 디자인의 차이점들이 지배적인 특징에 해당하며 이러한 차이점들로 인하여 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다. 반면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사여부 판단에서는 양 디자인에서 물품의 기능을 확보하기 위해 기본적으로 갖추어야 할 형상에 관한 판단 없이 양 디자인들의 차이점들은 통상의 디자이너가 쉽게 가할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하며, 양 디자인들의 공통점들이 주요 창작의 모티브를 이루는 동시에 전체 디자인의 지배적인 특징을 나타내는 것으로 보고 양 디자인은 유사하다고 판단하였다.

122) 자유실시디자인의 항변의 경우, 판례에서 '등록디자인과 대비되는 실시디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지거나'라고 하여, 등록요건에서의 판단 기준에 따라 판단하는 것으로 이해할 수 있다[권상한, "자유실시디자인 해당 여부 판단시 선행디자인의 표현 정도 [특허법원 2021. 8. 20. 선고 2021허2281 판결]", 『Law&Technology』, 제18권 제1호(2022), 86면에서도 자유실시디자인의 항변에서의 판단 방법은 신규성 내지 창작비용이성 판단과 다를 것이 없다고 설명하고 있다.].

권리의 속부 등 침해여부를 판단하는 장면에서는 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여 판단하도록 하고 있다.[123] 위에서 살핀 바와 같이, 디자인의 유사여부를 3가지 장면에서 각각 판단하게 되는 사안도 존재하는데, 공지부분을 포함하는 경우 유사여부에 관한 판단 기준이 달리 적용된다는 점에서, 위의 판결례와 같이 논리의 일관성이 결여될 가능성이 있다. 아울러, 이러한 판단 기준에 따라 공지부분의 중요도를 낮게 보고 판단하게 되면, 실질적으로는 해당 부분을 제외한 부분만을 중심으로 유사여부를 판단하게 되고, 복수의 공지된 디자인들을 참작하게 됨으로써 공지된 부분만이 아니라 유사한 범위까지 제외하여 판단하게 되어, 등록디자인의 유사 범위는 매우 좁게 설정되기 쉽다.[124]

나 주요국의 법리

(1) 일본

(가) 자유의장의 항변의 정의 및 의의

일본에서는 자유의장의 항변은, 무효의 항변(법 104조의 3), 무효의 항변설, 권리남용의 항변 등의 개념과 구별하여 사용되고 있다.

종래 일본에서는, 특허에 명백한 무효 사유가 있는 경우 무효의 항변을 인정해야 한다는 입장의 '무효항변설'이 존재해 왔는데, '무효항변설'의 경우 '명백하게 무효'가 될 것임이 전제가 되어야 한다는 점에서 일본 특허법 제104조의3의 '무효의 항변'과는 다른 의미를 가진다.[125] 다만, 이러한 무효항변설의 경우, 실제 채용되

123) 그 구체적인 판단 방법에 관해서는 박선하·양인수, "디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고 —한국과 일본의 비교를 중심으로—", 지식재산연구, 제17권 제1호(2022), 79-81면 참조.

124) 대상판결의 원심에서도 복수의 선행디자인들에 공지된 부분을 제외한 나머지 부분들을 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이라 인정한 결과, 확인대상디자인과는 유사하지 않다는 판단이 내려졌다. 대상판결에서는 신규성상실예외규정을 적용받는 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인의 항변을 주장할 수 없다는 점에서 디자인권자에게 유리한 판단이 내려짐으로써 디자인권을 강하게 보호하는 것으로 이해될 수도 있으나, 권리의 속부 판단 등의 실체판단에서는 공지된 부분의 중요도를 낮게 보고 판단하게 됨으로써, 등록디자인의 유사의 폭을 매우 좁게 하는 결과를 초래하고 있고, 이는 결국 등록은 되었으나 실질적인 권리를 행사할 수 없는 디자인권을 양산하게 만들어, 종국에는 디자인권의 형해화로 이어질 우려가 있는 것이다.

125) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 101-112면.

기 어려웠는데, 특허법 제104조의3이 도입되기 전 무효에 대한 판단은 특허청에서만 가능했기 때문에, 법원에서 무효를 판단하는 것은 실정법상의 문제로서 현실적으로 판단을 하기 어려웠으며, '당연무효(명백하게 무효)'라고 하기 위해서는 보통의 무효심판에서 제출된 자료만으로는 불충분하고, 누가 보아도 당연히 무효가 될 만한 자료를 근거로 입증을 하지 않으면 판단을 할 수 없다는 점에서도, 실무적으로는 무효항변설을 법원이 채용하기는 어려운 상황이었다.[126]

유사한 판단 논리를 가지는 '권리남용의 항변'도 존재하였다. 가령, 大阪地判 平成7. 10. 31. 平6(ワ)60 금속판 사건에서는 권리남용의 항변이 인정되었는데, 재판부는 등록의장이 출원 전 공지된 것으로 의장법 제3조 제1항 제1호(신규성) 위반으로 등록이 될 수 없음을 원고가 충분히 알고 있으면서도 출원을 하여 등록을 받은 것으로, 이러한 점을 참작하여 권리남용으로서 허용되어서는 안 된다고 판단하였다.[127] 이는 민법적인 권리남용의 항변을 인정한 사례로 여겨지는데,[128] 전부 공지된 특허발명, 실용신안등록 또는 등록의장에 의한 권리행사를 허용하지 않고, 특허 부여 관청에 의한 무효심결을 기다리지 않고, 신속한 분쟁의 해결을 민법에 근거한 법해석에 의해 실현한 것이다.[129] 즉, 특허권이나 디자인권을 근거로 하는 금지청구, 손해배상 청구는 해당 특허나 디자인에 무효 사유가 존재하는 것이 명백한 경우는, 특단의 사정이 없는 한, 권리의 남용에 해당하여 허용되지 않는다는 것이다.

126) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 101-112면.

127) 이 사건에서 재판부는 본건의장권의 의장등록에 명백한 무효사유가 있는 것만이 아니라, 그러한 무효사유가 본건등록의장의 의장등록출원을 한 원고 자신이 그 출원의 약 2년 반 전부터 본건등록의장의 실시품에 해당하는 금판(금판 A)을 제조판매하고, 이를 판매원을 통해서 중간 판매업자, 자동차부품 판매점 등에 유통시키고 있었고, 게다가 특허발명이나 등록실용신안에 관한 공지기술과 같이 그 평가가 사람에 따라 나뉘는 것과 같은 문제와는 달리, 원고가 제조판매하고 있던 금판 A의 의장이 본건등록의장과 동일한 실시품이라는 점에서 다른 해석이 들어갈 여지가 없다는 점에서, 원고는 이미 본건의장이 등록을 받을 수 없음을 충분히 알고 있으면서도 의장등록출원을 하여 등록을 받았다고 볼 수 밖에 없으며, 이러한 사정을 참작하면, 이러한 의장등록을 근거로 금지청구와 손해배상청구를 한 것은 권리 남용으로서 허용되어서는 안 된다고 판단하였다. 아울러, 피고는 권리남용이라는 주장을 명시적으로 하지는 않았으나, 권리남용의 근거가 되는 사실이 소송상 드러난 이상 재판부는 원고의 권리행사를 권리남용으로서 배척하는 것은 변론주의에 반하지 않는다고 판단하였다.

128) 末吉 亙, 앞의 글(주 130), 22면.

129) 三枝英二先生 · 小谷悦司先生還暦記念論文集 (著), 앞의 글(주 83), 867면[土肥一史 집필부분, "全部公知の意匠権の効力"].

위와 같은 권리남용의 항변을 근거로[130], 2004년 법원법 등의 일부를 개정하는 법률에 의해, 특허가 무효심판에 의해 무효가 되어야 함이 인정되는 때는 특허권을 근거로 한 권리의 행사는 허용되지 않는다고 하는 특허법 제104조의3 제1항(소위 '무효의 항변')이 신설되었다. 이에 따라, 의장법에서도 특허법 제104조의3 제1항을 준용하게 되었는데(의장법 제41조), 의장등록이 무효심판에 의해 무효로 될 것임이 인정되는 때는 의장권을 근거로 하는 권리의 행사는 허용되지 않는다고 하는 '권리행사제한의 항변으로서 무효의 항변'이 새로이 만들어지게 된 것이다.[131] 다만, 이처럼 특허법 제104조의3 규정이 도입됨으로써, 침해소송 법원과 특허청에서 특허권의 무효 여부를 판단할 수 있게 되어, 2가지 루트가 생기게 되었고, 이른바 무효판단의 양극화(더블트랙)라는 현상을 초래하게 되었으며, 결국 이러한 두 기관에 의한 판단에 모순이 생길 수 있음이 문제점으로 지적되어 왔다.[132] 즉, 이러한 규정에 의해, 특허청에서는 유효하다고 판단되더라도 법원이 무효라고 판단하여 결국은 권리를 행사할 수 없는 경우도 생기기 때문에, 이러한 현행 제도 하에서는 권리자 측이 특허권 침해소송의 제기를 주저하게 된다는 점이 문제로 지적된다.[133][134]

'자유의장(공지의장)의 항변'은 피고가 실시하고 있는 물건이 가령 출원 전에 공지된 경우, 의장권권의 범위와는 상관없이, 비침해의 영역에 포함되므로, 원고는 권리행사를 할 수 없다는 것이다.[135] 東京地判 平成 9. 4. 25. 平5(ワ)17437 고무

130) 最高裁判所 平成12. 4. 11. 平10(オ)364 키르비 사건

131) 末吉 亙, 『新版 意匠法〈第3版〉【知的財産法実務シリーズ】』, 中央経済社, 2017, 22-23면.

132) 小池 豊, "特許法104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見", 『パテント』, Vol. 63, No. 8(2010), 107면.

133) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 107면.

134) 무효의 항변은 침해소송에서 종래 행해온 기술적 범위의 한정해석을 할 필요 없이 타당한 결론에 이르게 할 수 있는 항변으로, 또한 법률의 명문화가 인정되어, 주장할 수 있는 사유가 법정되어 있는 항변으로 그 적용범위가 명확하다 할 수 있으며, 나아가서는 무효사유로서도 신규성, 진보성이라고 하는 공지기술과의 관계를 문제로 하는 사유만이 아니라, 기재불비(특허법 36조)를 포함한 넓은 범위의 사유를 주장할 수 있기 때문에, 침해소송 실무에서는 매우 유용한 항변이라 평가된다. 다만, 특허의 경우, 무효의 항변에 대한 재항변으로 정정이 인정되는데, 이에 의해 침해소송의 심리가 지연된다는 문제점이 있으며, 통상적으로 침해소송이 제기되는 경우 무효심판도 동시에 제기되어, 특허청과 법원의 판단이 일치한다는 보장이 없다는 점에서 문제로 지적된다[牧野知彦, "侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁", 『知財管理』, 58巻4号(2008), 474면].

135) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 112면.

줄 사건 판결에서는 “의장등록을 무효로 한다는 심결 청구를 할 수 있는 것과는 별도로, 자기가 실시하고 있는 의장이 해당 등록의장과의 관계에서 공지의장과 동일 또는 실질적으로 동일함을 주장하고, 입증하면, 해당 등록의장의 범위에 포함하지 않는다는 의미에서의 청구권불발생의 항변(출원전 공지의장의 항변)을 할 수 있다고 이해하는 것이 상당하다.”라고 판시하였는데, 자기가 실시하고 있는 물건 등이 공지된 것임을 주장하면 권리 행사를 막을 수 있기 때문에 특허법 제104조의3이 규정된 이후에도 유효한 항변 중 하나로 평가된다.[136][137] 해당 판결에서는 그 이유로서 의장법 제3조 제1항은 등록의장의 범위에는 공지의장 및 공지의장과 유사한 의장은 포함하지 않는 것을 규정한 것으로 해석할 수 있는데, 이에 의장권의 효력이 등록의장 및 이와 유사한 의장에 미치도록 하는 의장법 제23조의 규정을 함께 고려하더라도, 등록의장의 의장권의 효력은 적어도 해당 등록의장과의 관계에서 공지의장에는 미치지 않는다고 하는 것이 의장법의 조문의 취지라 이해할 수 있고, 이뿐 아니라, 실질적으로 생각하더라도 공지의장의 존재에 의해 무효사유가 있음에도 이를 간과하여 등록된 의장권에 기초하여 해당 공지의장과 동일한 의장의 실시에 관해 금지청구권을 인정하는 것은 바람직하지 않다고 판단한 것이다. 자유의장의 항변의 명확한 근거 규정은 없으나, 위의 판결에서의 이유처럼 권리는 출원시 의장의 수준을 상회하는 성과물에 부여하지 않으면 안 된다는 산업적인 창작보호를 실현하는 지적재산제도에 내재하는 것으로, 의장법 제1조 및 제3조 등에 근거한다고 볼 수 있을 것이다.[138]

---

136) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 113면.

137) 특허침해소송에서는 大阪地方裁判所 昭和45年4月17日 昭和42(ワ)412 金属編籠 사건에서 처음으로 자유기술의 항변이 주장되어 채용되었으나, 2심(大阪高裁)에서는 부정되었다. 이후 東京地判 平成 9.4.25 (平成5年 (ワ) 第17437号) [ゴム紐 (意匠) 一審] 、東京高判 平成 10.3.25 (平成9年ネ) 第2248号) [ゴム紐 (意匠) 二審] (2심에서는 원심을 인용함) 판결에서 채용된 후, 특허침해소송에서도 자유기술의 항변을 주장할 수 있다는 견해가 있었으나, 실무적으로는 특허법 제104조의3 (무효의 항변)과 균등론의 제4요건(공지기술로부터 용이 추고)이 주로 주장되어, 자유기술의 항변 자체는 거의 주장되고 있지 않다. 다만, 최근에는 오히려 그 중요성이 높아지고 있다는 견해도 제시되며 [田中汞介, 自由技術の抗弁の現代的意義, 2021. 12. 21. https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312, 검색일: 2024. 9. 6.], 소송실무적인 관점에서 침해소송의 피고의 입장에서 주장 가능한 항변이 많은 것이 선택의 폭이 넓다는 점에서 자유기술의 항변은 의미가 있다는 견해도 제시된다[牧野知彦, 앞의 글(133), 480면].

138) 三枝英二先生 小谷悦司先生還暦記念論文集 (著), 앞의 글(주 83) 868면[土肥一史 집필부분, “全部公知の意匠権の効力”].

자유의장의 항변은 대상물건이 의장권의 권리범위에 속하는지 여부를 묻지 않고, 자기가 실시하고 있는 의장이 공지의장이라면 침해를 벗어날 수 있는 것으로, 이는 공지의장은 만인 공유의 공유재산이라고 하는 의장법의 근본원리에 입각한 것이다.[139] 일본의 경우 실무적으로 자유의장의 항변이 거의 주장되고 있지는 않으나, 자유의장의 항변의 경우 자신의 실시물건 등이 어떠한 공지의장과 동일 또는 유사하다는 것만을 주장하면 되기 때문에 그 입증이 상대적으로 편리한 반면, 무효의 항변의 경우 증거수집 등에서부터 시작해야 하기 때문 상대적으로 부담이 된다는 점에서 그 의의가 있다고 평가된다.[140] 특허의 자유기술의 항변에 관한 설명이기는 하나, 소송 경제성 등의 측면에서 자유기술의 항변의 중요성이 강조되고 있다는 점에서 무효의 항변 등이 규정된 현재로서도 이러한 항변은 유효한 것으로 평가된다.[141]

(나) 자유의장의 항변의 판단범위

일본에서 자유의장의 항변은 침해소송을 합리적으로 처리할 수 있는 것을 목적으로 운영되어온 것이라는 점을 고려하면 그 범위가 제한되어 운영되어 왔다. '고무줄 사건' 판결에서는 실시의장이 공지의장과 '동일하거나 실질적으로 동일'한 경우에 자유의장의 항변이 인정됨을 판시하고 있는데, 자유의장의 항변에 대한 일본 법원의 엄격한 해석론을 간접적으로 확인할 수 있는 것이라고 평가된다.[142]

특허법 상 자유기술의 항변에 관한 논쟁이기는 하나, 공지기술의 항변을 인정하는 견해들 중에서 반드시 일치하지 않는 부분이 있는데, 그 하나는 공지기술이 어디까지 확장하여 공지기술의 항변을 인정하는지에 관해서이다. 이에는 침

139) 小橋 馨, "特許法104条の3と公知技術の抗弁", 『近畿大学法科大学院論集』, 4号(2008), 11면.

140) 牧野利秋 編, 앞의 글(주 45), 55면.

141) 2016년 심사기준 개정에 의해 식품용도발명이 인정되게 되면서, 그 실시가 실질적으로 공지기술(공지물질의 공지의 이용방법)과 구별할 수 없는 발명까지 특허가 부여되는 것이 우려되고 있고, 식품용도발명 이외에도 그 실시가 실질적으로 공지기술과 구별할 수 없는 것으로 여겨지는 용도발명에 관해 신규성을 인정하는 재판례가 생기게 되면서, 이러한 용도발명에 관한 특허권 행사에 대해서 자유기술의 항변의 주장은 의의를 가지는 것으로 여겨진다[田中汞介, "自由技術の抗弁の現代的意義(特許法の八衢)", 2021. 12. 21. https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312(최종검색일: 2024. 9. 6.)].

142) 末吉 亙, 앞의 글(주 130), 21-22면.

해자가 실시하고 있는 기술이 공지기술과 동일인지, 또는 공지기술과 근사한 것인지에 한정되어야 한다는 견해와,[143] 공지기술로부터 용이하게 상도할 수 있는 것이 명백한 경우에 한정되어야 한다는 견해,[144] 공지기술로부터 용이하게 상도할 정도까지 인정해야 한다는 견해가 있다.[145] 특허출원시의 공지기술로부터 용이 상도 가능한 범위(편의적으로 '진보성의 범위'라고 함)의 기술까지 자유기술의 항변을 인정하는 견해는 존재하기는 하나 소수에 그치며,[146] 공지기술과 근사 또는 실질적으로 동일한 범위의 기술까지만 자유기술의 항변을 인정한다는 견해가 다수설인 것으로 이해된다.[147]

(다) 의장의 유사여부에 의한 침해판단에서 공지의장의 참작

일본의 권리행사단계의 유사여부와 관련한 현행의 판단방법은 '등록의장과 피의침해의장이 유사한지'라고 하는 양 의장을 등치하는 관점에서 보는 것이 아닌, '피의침해의장이 등록의장과 유사한지'라고 하는 관점, 즉, 등록의장의 유사 범위 내에 피의침해의장이 포함되는지 라고 하는 관점에서 이루어진다.[148] 즉, 이러한 현행 판단 방법에서는 공지의장에는 없는 신규한 창작부분의 존재 등을 참작하여 수요자 등에게 가장 주의를 끌기 쉬운 부분을 의장의 요부로 파악하고, 등록의장의 창작의 실질적 가치를 탐구함으로써, '등록의장의 범위(의장법 24조 1항)'를 정하고, 등록의장과 피의침해의장이 등록의장의 요부에 있어서 구성 태양을 공통으로 하고 있는지 라는 관점에서 판단한다.[149]

---

143) 小橋 馨, 앞의 글(주 143), 17면.

144) 松本重敏,『特許発明の保護範囲 新版: その理論と実際』,有斐閣, 2000, 315면; 小橋 馨, 앞의 글(주 143), 17면.

145) 大瀬戸 豪志, "特許侵害訴訟における自由技術の抗弁", 『パテント』, 46巻7号(1993), 21면.

146) 松本重敏, 앞의 글(주 148), 287면.

147) 牧野知彦, 앞의 글(주 133), 478면; 小橋 馨, 앞의 글(주 143), 7면; 田村善之,『知的財産法〔第5版〕』, 有斐閣 , 2010, 274면.
기본적으로는 자유 기술의 항변을 인정하는 범위를 특허 출원 시의 공지 기술과 실질적으로 동일한 것까지로 하고, 특허 출원시의 공지 기술과 침해(판단)시에서 보면 균등한 기술(실질적으로 동일)도, 자유 기술의 항변의 범위에 포함될 여지가 있다고 보는 견해도 있다[古城春実, "特許侵害訴訟と公知技術", 『日本工業所有権法学会』, 年報29号(2006), 60-63, 65-66면].

148) 加藤 幹,『パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論』, 知的財産法学の新たな地平. 2022, 260면.

149) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 260-261면.

의장의 유사판단에 있어서, 공지의장은, 의장권침해사건에서는 본건 등록의장의 권리범위의 설정, 요부의 인정에서 참작되며, 심결취소청구소송에서는, 본원의장의 창작과 관련한 의장적 가치 평가에 있어서 참작된다.[150] 다만, 등록의장의 범위를 정하기 위한 공지의장의 참작과 공지의장제외설에서의 공지의장의 참작은 다르다.[151] 즉, 등록의장의 범위를 정하기 위한 공지의장의 참작은 항상 필요한 것인 반면,[152] 공지의장제외설에서의 공지의장의 참작은 등록의장의 범위 내에 공지의장이 포함되는 경우에 비상(非常)의 수단으로서 필요한 것이다.[153][154] 공지의장의 범위 내에 공지의장이 포함되는 경우, 이전에는 비상(非常)적인 수단으로서 등록의장의 범위가 공지의장을 포함하지 않도록 하기 위해 공지의장을 참작할 필요가 있었는데, 특허법에서의 '특허의 부여는 일정한 공정력을 가지는 것이기 때문에, 특허무효의 확정 심결이 없는 한, 아무도 특허에 의해 부여된 효력을 부정할 수 없으며, 따라서 법원도 등록된 특허권의 효력을 무효심결을 거치지 않고 직접 선언할 수 없다'라는 개념이 의장법에서도 적용되었기 때문이었다.[155] 즉, 특허법에서의 공지기술제외설은 '기술적 범위를 확정하는 때 공지기술을 참작(제외)하여 한정 해석함으로써, 대상 제품을 권리범위로부터 제외하고, 특허의 당부 및 그 효력에 대해서는 판단하지 않고, 사안의 구체적 타당한 해결을 도모하기 위한 해석 방법으로서 발달해온 것'으로 이해되는데, 의장법에서의 공지의장제외설에도 과오 등록된 의장에 관한 의장권의 행사를 방지하기 위한 것으로 의의가 있었다.[156] 하지만, 무

150) 吉田親司,『意匠の理論(現代産業選書—知的財産実務シリーズ)』, 経済産業調査会, 2017, 291면.

151) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 270면.

152) 知的財産高等裁判所 平成２２年（ネ）第１００１４号 사건에서는 항소인이 의장의 유사판단에서 공지의장을 참작하는 방법을 허용해서는 안 된다는 취지의 주장을 하였는데, 이에 대해 재판부는 무효의 항변이 규정된 이후에도 공지의장의 참작은 필요하다고 하여 항소인의 주장을 배척하였다. 다만, 공지의장의 참작은 등록의장이 구비하는 창작성의 폭을 검토하기 위한 것이라 설시하였다.

153) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 270면.

154) 斎藤瞭二,『意匠法』, 発明協会, 1985, 193면에는 '권리의 형식적 유효성을 전제로 하면서, 제3자의 이익과의 형평을 확보하려고 하는 공지사항제외설은, 침해사건의 각 건에서 각각의 사정을 근거로 법적 정의를 실현하려고 하는 특수 해석인 것으로, ... 일반적 유사 판단의 기준으로서는 전제하는 사실이 다르며, 개념의 기초도 다른 것이다'라고 하여, 이론적으로 구별되어야 함을 설명하고 있다.

155) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 256-257면.

156) 斎藤瞭二, 앞의 글(주 158), 187-194면; 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 265-266면.
斎藤는 공지의장제외설을 공지기술제외설에 대응하는 비상의 수단으로 위치하는 것으로 설명한다.

효이 항변이 인정되어 의장법에서 권리행사제한의 항변이 규정된 현재에 이르러서는, 과오 등록된 의장에 관한 의장권의 행사에 대해 무효의 항변을 주장하면 되기 때문에, 학설에서 지적하는 바와 같이 공지의장제외설은 현재로서는 존재의 의의가 빈약하다 할 것이다.[157] 특히, 종래의 공지의 의장에 의장권의 효력이 미치지 않도록 공지의장을 참작해야 한다고 보는 견해에 따라 공지의장을 참작하게 되면, 공지의장과 동일하지 않고 유사한 의장까지 등록의장의 유사 범위로부터 제외되기 때문에, 단순히 공지의장을 제외하는 것 이상으로 등록의장의 유사 범위는 좁게 설정되기 쉬운 문제점도 있다.[158]

(2) 중국

중국은, 현행 전리법 제67조에 자유실시디자인의 항변에 대응되는 "현유기술(現有技術, 디자인 포함)의 항변"을 규정하고 있는데, 자유실시디자인에 대응되는 이론을 법률상 명문의 규정으로 도입하고 있는 유일한 국가라고 볼 수 있다.[159] 다만, 현유기술의 항변은 그 판단방법에 관한 명확한 기준이 없었기 때문에, 법원에 따라 구체적 판단방법이 달리 적용되어 왔는데, 중국의 최고법원은 最高裁判所 (2010) 民提字第189号 판결에서 현유기술의 항변의 판단 방법을 구체적으로 제시하였다.[160][161]

---

157) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 266면.

158) 加藤 幹, "意匠の類否判断における公知意匠の参酌", 『パテント』, Vol. 74, No. 8(2021), 68면.

159) 정태호, 앞의 글(주 48), 668면.
중국에서 디자인은 전리법(특허법)에 의해 보호되는데, 전리법 제67조(제3회 개정)에서는 '전리권 분쟁에서 피의침해자가 그 실시하는 기술 또는 디자인이 기존 기술 또는 기존 디자인에 속하는 것을 증명하는 증거를 가지는 경우, 전리권 침해를 구성하지 않는다.'고 규정하고 있다.

160) 브리지스톤사는 타이어에 관한 의장권을 소유하고 있었는데, 公牛社가 제조한 타이어가 자사의 타이어 디자인과 매우 유사한 것을 발견하고 2006년 의장권침해소송을 제기하였다. 소송에서 公牛社는 현유기술의 항변을 주장하였는데, 1심에서는 현유기술의 항변을 적용하는 경우에는 피의침해제품과 공지디자인만을 대비하여 동일 또는 유사한지 여부를 판단하면 충분하다고 함으로써, 피의침해제품과 공지디자인이 유사하다는 이유로, 현유기술의 항변이 인정되었다. 2심인 고등법원에서는 양 디자인이 유사하다고 판단하였는데, 브리지스톤사가 주장한 차이점은 전체적인 시각효과에 현저한 영향을 미치지 않기 때문 양 디자인은 유사하다고 판단하였다.

161) 중국대법원은 '유사 여부를 판단할 때는 단지 피의침해제품과 공지디자인에 대해서만 대비하게 되면 양 디자인의 차이점 및 해당 차이점이 양 디자인의 전체적인 시각 효과에 미치는 영향을 무시할 우려가 있고, 이에 의해 잘못된 판단을 할 수 있기 때문에, 피의침해제품의 디자인과 공지디자인, 등록디자인의 3자가 모두 유사하다는 상황이 생기게 된다. 따라서 피의침해제품과 공지디자인이 동일하지

"①공지디자인과 피의침해제품을 비교하여 동일한 경우 공지디자인의 항변이 성립하여 침해는 성립하지 않는다, ②공지디자인과 피의침해제품이 동일하지 않은 경우, 공지디자인을 기준으로, 공지디자인과 피의침해제품, 등록의장의 3자를 각각 대비하는데, 피의침해제품은 등록디자인과 공지디자인과의 차이점을 이용하였는지, 전체적인 시각 효과에 대한 영향 등에 근거하여, 피의침해제품이 공지디자인과 유사한지, 등록디자인과 유사한지 여부를 판단한다."라는 2단계의 과정을 통해 판단하도록 구체적인 판단 방법을 제시하였다.[162] 이러한 판단방법에 따라, ①피의침해제품과 공지디자인은 동일하지 않으며, ②피의침해제품과 등록디자인, 공지디자인의 3자의 차이점을 고려하면, 등록디자인과 공지디자인의 차이점은 시각효과에 대해 현저한 영향을 미치며, 피의침해제품은 이러한 차이점들을 모두 이용하고 있고, 이러한 차이점들은 피의침해제품과 공지디자인 사이의 차이점을 구성하므로, 피의침해제품과 공지디자인과의 유사점과 비교하여 이러한 차이점은 양 디자인의 전체적인 시각효과에 현저한 영향을 미치는 것으로 판단하여, 공지의장의 항변은 인정하지 않았다.

다 개선점

(1) 창작비용이성 판단의 확대 적용의 제한

우리나라의 경우 자유실시디자인의 항변은 등록디자인과 대비되는 디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지는 경우(신규성이 없는 경우)만이 아니라, 이러한 공지디자인 또는 공지디자인들의 결합에 의해 쉽게 실시할 수 있는 경우(창작비용이성이 인정되지 않는 경우)까지도 인정되어, 공지디자인과 동

않은 경우에는 디자인권 침해에 대해 정확한 결론을 내리기 위해, 공지디자인을 기준으로 피의침해제품의 디자인과 공지디자인과 등록디자인의 3자에 대해 각각 대비한 다음 종합적으로 판단해야 한다. 그 과정에서 피의침해제품과 공지디자인의 차이점과 유사점 및 전체적인 시각효과에 미치는 영향에도 주의해야 하며, 피의침해제품이 등록디자인과 공지디자인의 차이점을 이용했는지 여부를 고려한 후, 피의침해제품의 디자인과 공지디자인에 실질적인 차이점이 존재하는지 여부를 판단해야 한다.'라고 판시하였다.

162) 北京魏啓学法律事務所, "意匠権侵害訴訟における公知意匠の抗弁", https://www.raytec.co.jp/application/files/9915/4139/2531/201105-IPSP8.pdf, 최종 검색일 2024. 9. 6.

일한 경우에만 인정되는 중국이나, 실질적으로 동일한 경우까지만 인정하는 일본보다 그 인정범위가 상대적으로 넓다. 미국의 경우 균등론을 제한하기 위한 법리로서 자유실시 기술의 항변에 해당하는 가상클레임의 법리가 특허침해소송에서는 허용되나, 균등론이 존재하지 않는 디자인 특허에는 자유실시디자인의 법리가 허용되지 않는다. 독일의 Formstein 항변, 영국의 Gillette 항변도 존재하나,[163] 이러한 항변들 역시 특허에서의 균등의 항변으로서만 사용될 뿐 디자인보호법에서 사용될 수 있는 것은 아니다.

한편, 선출원주의 하에서는, 출원을 하여 디자인등록을 받은 디자인권자와 별개로 동일하거나 유사한 디자인을 실시하는 경우 디자인권 침해에 해당할 수 있는데, 등록디자인의 출원 전에 선의로 해당 디자인을 실시하고 있는 자에 대해서는 법으로 선사용에 따른 통상실시권을 부여하여 침해로부터 보호하고 있다.[164] 이러한 선사용권은 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시 등에 그 범위를 한정하고 있는데, 자유실시디자인의 경우 공지디자인의 결합 등에 따라 용이하게 창작 가능한 정도까지 인정한다는 점에서, 자유실시디자인으로 인정되는 범위가 상대적으로 넓다고 볼 수 있다. 대상판결에서도 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여하는 것은 바람직하지 않다고 판시하고 있다는 점에서도, 공지된 디자인에 실질적인 기여가 없음에도 불구하고, 자유로운 실시가 해당 공지디자인을 넘어선, 2이상의 복수의 공지디자인의 결합에까지 무상의 실시 권한을 부여해도 되는 것인지는 의문이다.

따라서, 우리나라도 장기적으로는 자유실시디자인을 동일범위(또는 동일·유사범위)까지만 한정하고, 용이창작 범위에 대해서는 허용하지 않는 방향으로 실무를 변경할 필요가 있다고 생각된다. 다만, 현실적으로는 용이창작 범위까지 허용하는 자유실시디자인의 항변의 법리가 굳건히 사용되고 있는바, 당장은 그 적용을 제한하는 방향으로 제도를 검토할 필요가 있다. 우니나라의 경우 디자인보호법 개정을

163) 정차호, 앞의 글(주 41), 278-279면.

164) 디자인보호법 제100조(선사용에 따른 통상실시권) 디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

통해서 디자인등록요건인 창작비용이성 판단의 비교대상자료를 계속 확대하여 왔는데,[165] 이에 따라 자유실시디자인의 항변의 판단 시의 비교대상디자인의 자료도 함께 확대되어 왔다고 볼 수 있을 것이다.[166] 자유실시디자인의 영역이 디자인등록출원된 디자인이 등록을 받을 수 없는 영역, 즉 신규성이나 창작비용이성이 부정되어 차단효가 있는 독점·배타권을 확보할 수 없는 영역이라고 본다면, 등록요건상 창작비용이성 판단의 비교대상자료와 자유실시디자인의 항변 판단의 비교대상자료는 같아야 논리적이라 할 것이다.[167] 그럼에도 불구하고, 앞에서 살펴보았듯이 4개 이상의 복수디자인들의 결합에 의해 용이창작이 가능하다는 이유를 들어 자유실시디자인으로 인정하는 경우도 있고, 이러한 실무적 판단은 자유실시디자인의 항변의 남용으로도 이어질 수 있다는 점에서, 비교대상자료를 제한할 필요는 있을 것이다.

특히, 디자인권은 다른 지식재산권과 비교하여 모방에 특히 취약하고 그 구제는 충분하지 않은 경우가 많은데, 이러한 상황에서 자유실시디자인의 적용 범위를 창작용이성까지 확대 적용하면서, 선행디자인의 적용 범위 등에 대해서 제한을 두지 않는다면, 실질적으로 디자인권의 유효성까지 부정하는 결과를 초래하게 될 것이

165) 윤선희·이승훈, “자유실시디자인의 항변의 판단 시 고려할 사항 - 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결-”, 『법조』, 제66권 제2호(2017), 795-796면.
아울러, 구체적 개정내용은 정상조 외 3인 공편, 앞의 글(주 108), 300-302면(유영선 집필부분) 참조[1961. 12. 31. 법률 제951호로 제정된 구 의장법에는 디자인의 등록요건으로 신규성만 규정하였고, 창작비용이성 요건은 규정하고 있지 않았다. 그 후 1973. 2. 8. 법률 제2507호로 전부 개정된 구 의장법에 창작비용이성 요건을 신설하였는데, 현행 디자인보호법 제33조 제2항 제1호(공지되거나 공연 실시된 디자인)에 대응하는 규정만 있었고, 제2호(주지 형상 등)에 대응하는 규정은 두고 있지 않았다. 1980. 12. 31. 법률 제3327호로 개정된 구 의장법에는 ‘주지형상 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 추가되었다. 한편, 1990. 1. 13. 법률 제4208호로 전부 개정된 구 의장법에서는 제5조 제2항에서 ‘공지디자인 등’에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 삭제하고, ‘주지형상 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인만을 남겨두었으나, 2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정된 구 디자인보호법에서는 ‘주지형상 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 외에 ‘공지디자인 등’에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 추가하였다. 이후 2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정된 디자인보호법에서는 제33조 제2항 제1호에 ‘공지디자인 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인을, 제2호에는 ‘주지형상 등’에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 나누어 규정하는 한편, ‘주지형상 등’의 범위를 국외까지 확대하였다.].

166) 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서는 ‘국내에서 널리 알려진 형상 · 모양 · 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것’이라고 판단하였고, 이후 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 ‘공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 때’라고 판단하여 그 인정범위를 넓혀 왔다.

167) 윤선희·이승훈, 앞의 글(주 169), 798-799면.

다. 산업정책적 규정이라고 볼 수 있는 창작비용이성 규정에 의한 유효성 부정은 예외적인 경우에 한해 인정되어야 한다는 점에서도 그 유효성 판단에 인용될 수 있는 선행디자인에는 엄격한 기준을 요구할 필요가 있다.[168]

(2) 디자인 유사여부 판단기준의 정합성 제고 및 등록디자인의 고려

디자인의 유사여부를 자유실시디자인 항변에서의 확인대상디자인과 공지디자인의 유사여부 판단, 등록디자인의 무효여부 판단, 권리범위 속부 판단이라는 3 가지 장면에서 각각 판단하게 되는 사안도 존재하는데, 공지부분을 포함하는 경우 유사여부에 관한 판단 기준이 달리 적용된다는 문제점이 있다. 미국[169]이나 일본 등의 경우, 기본적으로는 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 동일한 판단 방법이 적용된다는 점에서, 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 상이한 유사여부 판단방법을 채용하고 있는 우리나라와는 그 운용이 다르다. 실제로 권리범위확인심판 등에서 권리화단계와 권리행사단계에서의 유사여부 판단기준이 달라, 서로 모순되는 결과가 충분히 도출될 수 있다는 점에서, 주요국과 같이 판단기준을 통일할 필요가 있는 것으로 생각된다.

한편, 일본이나 중국 등 주요국에서는 자유실시디자인의 판단에 관하여 실시디자인, 공지디자인 및 등록디자인 3자를 비교하여 판단하는 방법을 적용하고 있어, 사실상 실시디자인과 공지디자인만의 절대적인 비교로 비침해 결론을 도출하는 법리는 찾아보기 어렵다는 점도 지적된다.[170] 이러한 법리는 실시디자인이 공지디자

168) 안원모, 앞의 글(주 123), 144면.

169) 미국의 경우, Door-Master 사건 판결에서 연방순회항소법원(CAFC)은 '실용특허과 동일하게 의장특허에서 신규성이 상실되려면, 단일한 인용예가 특허청구된 의장과 "모든 중요한 점에 있어서 동일"할 것을 입증할 필요가 있다. 의장특허침해의 판단 기준은 의장 특허의 신규성 상실에도 적용된다. ... 침해 또는 신규성 상실이 인정되기 위해서는 2개의 디자인이 실질적으로 동일하지 않으면 안 된다.'라고 판시한바 있는데, 미국에서는 등록여부 판단과 침해여부 판단에서의 디자인의 유사 여부 판단 방법은 동일한 것으로 여겨지고 있다[Sarah Burstein, 앞의 글(주 119). 613-615면; 末宗達行, "アメリカにおけるデザインの保護", 『デザイン学研究特殊号』, Vol.25-2 No.98(2017), 31-32면]. ("[t]hat which infringes, if later, would anticipate, if earlier,")'라는 특허의 격언은 디자인특허에서도 적용된다(통상의 관찰자 테스트). 다만, Burstein는 디자인의 실질적인 동일성의 폭이 지나치게 좁다는 점을 지적하고 있는데, 법원에서의 디자인의 동일성의 폭을 좁게 보는 한 심사 단계에서의 신규성에서의 동일성의 판단의 폭도 좁아질 수 밖에 없다는 견해를 제시하고 있다[Sarah Burstein, 앞의 글(주 119)].

170) 정태호, 앞의 글(주 48), 680면.
즉, 중국, 일본 등에서의 해석론에 따르면, 자유실시디자인의 판단이 형식상으로는 공지디자인과 실

인 등으로부터 용이하게 실시 가능한지 여부를 판단할 때, 등록디자인과의 비교를 통해 사후적 고찰을 막는다는 점에서 유효하다 할 수 있을 것이다. 가령, 특허법원 2022. 6. 23. 선고 2021허2892 판결에서는 확인대상디자인이 선행디자인 1에 선행디자인 4 또는 선행디자인 1에 선행디자인 4, 6의 결합에 의해 용이하게 창작 가능한 것으로 판단하였는데, 확인대상디자인과 비교대상디자인 1 및 선행디자인 4의 차이점에 해당하는 캐리어형태의 내부에 소화전(소화기가 아닌 소화전 자체)이 설치되고 그 측벽에 인입구를 형성하는 구성은 등록디자인의 주요 특징부로서, 이러한 특징들이 등록디자인에 의해 개시되기 전에는 이러한 구성들을 모두 구비한 디자인은 공지되지 않았다고도 볼 수 있다. 즉, 확인대상디자인이 선행디자인 1, 4 등에 의해 용이하게 창작 가능한 자유실시디자인에 해당한다는 판단은, 등록디자인의 개시에 의한 사후적 고찰이라고도 볼 수 있을 것이다. 이런 점에서 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를 판단할 때, 복수의 선행디자인들에 개별 구성들이 단순히 개시되었다는 점만을 판단하는 것이 아니라, 이러한 복수의 구성들을 결합함에 있어서 등록디자인의 개시가 영향을 미쳤는지 여부를 판단하는 것도 필요하다고 생각된다.

6 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계에 대한 검토

가 대상판결이 제시한 관계 및 이에 대한 평가

(1) 대상판결이 제시한 관계

대상판결에서는 “자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용

시디자인만을 비교하는 것처럼 되어 있으나, 실제적으로는 등록디자인의 권리범위와의 관계도 아울러 고려해서 판단해야 하는 것임을 지적한다. 앞에서도 살펴보았듯이, 중국의 경우 대법원 판례에서 등록디자인, 실시제품디자인, 공지디자인 3자를 비교해서 판단해야 함을 명확히 설시하였고, 일본의 경우에도 고무줄 사건 판결에서 자기가 실시하고 있는 디자인이 해당 등록의장과의 관계에서 공지디자인과 동일 또는 실질적으로 동일인지를 주장하면 되는 것으로 설시한바 있다.

할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다."라고 하는 한편, "디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다."고 판시함으로써, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 하는 자유실시디자인의 항변이 인정되지 않음을 명백히 밝혔다.

(2) 평가

자유실시디자인의 항변과 신규성 상실의 예외의 인정효과에 관해 종래에는 명확한 해석론이 존재하지 않았으나, 일부 하급심 판결에서는 신규성 상실의 예외가 인정되어 등록된 공지디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당되지 않는 것으로 판단하여 이를 근거로 한 자유실시디자인의 항변은 인정할 수 없음을 판시하고 있었고,[171] 신규성 상실의 예외 규정의 존재 의의, 디자인 출원 이후 실시한 자를 보호할 법적 필요성이 있는지 등을 고려할 때, 신규성 상실의 예외 적용을 받아 등록된 디자인의 효력을 우선하여 그 권리범위를 인정하는 것이 타당하며, 그렇지 않은 경우 디자인권은 전혀 권리범위를 누릴 수 없는 형해화된 권리로 전락하게 된다는 견해가 제시되었다.[172]

반면, 원심에서와 같이 신규성 상실의 예외 규정이 인정된 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변을 허용한 판결도 존재하였다. 신규성 상실의 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 예외 규정을 도입한 취지에 반하게 되며, 디자인보호법은 이러한 예외를 인정받을 수 있는 시기를 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는바 이러한 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있기 때문이라는 이유 등을 들고 있다.

171) 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 2016가합502475, 575398(병합) 판결 등.
172) 신기현, 앞의 글(주 2), 56면.

대상판결에서는 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판시함으로써, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 하는 자유실시디자인의 항변이 인정되지 않음을 처음으로 명백히 밝혔다. 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인에 근거한 자유실시디자인의 항변을 인정하는 경우 디자인권의 형해화를 초래할 수 있다는 점에서, 법 목적 및 취지를 고려하여 디자인권의 보호에 힘을 실어줬다는 점에서 의의가 있다. 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인은 그 유래가 퍼블릭 도메인이라는 누구나 사용해도 되는 디자인에서 온 것이 아닌, 독점권이 부여된 등록디자인에 유래한 것이라는 점에서도 자유실시디자인의 항변이 허용되지 않는다는 것은 당연한 결론일 것이다.

신규성 상실의 예외 적용을 받아 등록된 디자인의 효력을 제한하는 규정은 존재하지 않기 때문에, 원칙적으로 디자인으로서 온전한 권리를 누린다고 보아야 할 것이다.[173] 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변은 '디자인의 출원 전 공지'라는 동일한 사실에 대하여, 서로 이해가 상충하는 자들에게 각각 유리한 법적 효과를 부여하고 있다고 볼 수 있는데, 신규성 상실의 예외 제도는 출원 전 공지되었다고 하더라도 디자인권을 부여하여 독점·배타권을 누릴 수 있도록 하는 반면, 자유실시디자인의 항변은 출원 전 공지되었다는 이유로 제3자의 자유로운 실시를 보장하는 것이다.[174] 다만, 신규성상실예외 규정을 적용받아 등록된 디자인권의 효력을 우선한다면, 공지를 신뢰하고 디자인을 실시한 실시권자에게 불측의 손해를 줄 수 있는 반면, 해당 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변을 허용한다면 신규성상실예외 규정을 적용받아 등록된 디자인권의 효력이 형해화되어 해당 제도의 취지가 몰각될 우려가 있을 것이다.[175]

대상판결에서 판시한 바와 같이, 자유실시디자인의 항변에서의 공지디자인은 단

173) 신기현, 앞의 글(주 2), 52면.
174) 신기현, 앞의 글(주 2), 52면.
175) 신기현, 앞의 글(주 2), 46면.

순히 형식적으로 공지되었다고 하여 해당 디자인을 무조건 근거로 삼을 수 있는 것은 아니다. 공지디자인이 실제적으로 만인공유의 자유로운 실시 영역의 범주로 작용할 수 있을 때 자유실시디자인에서의 공지디자인으로 볼 수 있는 것이다.[176] 자유실시디자인의 항변이란 침해행위를 하였다는 상대방이 실시하는 디자인이 '디자인권자의 등록디자인으로부터 유래된 것'이 아니라, 해당 등록디자인의 출원 이전에 이미 자유롭게 누구나 활용할 수 있는 공지·공용의 선행디자인이거나 그로부터 쉽게 도출할 수 있는 디자인에 불과하다고 다투는 항변인 것이다.[177] 근본적인 개념을 고려해 볼 때에 공지디자인에 대하여 디자인권자가 신규성 상실의 예외를 인정받아 디자인권을 확보한 이후 이와 동일 또는 유사한 디자인을 침해주장을 받는 상대방이 실시하고 있을 경우, 이러한 실시행위는 이미 공지디자인이 해당 디자인권의 독점권의 영역으로 들어가 등록디자인과 일체화된 상황에서 이러한 등록디자인에 유래한 것으로 보아야 하므로, 이미 독점권이 부여된 공지디자인에 유래된 것으로서 당연히 자유실시디자인의 항변이 허용되지 않는다고 보아야 함이 타당한 것이다.[178] 이미 특정 거래시장에서 공유물로 되어 있는 디자인이거나 공중이 자유롭게 실시할 수 있는 디자인일 것이라는 공중의 기대가 형성된 디자인의 경우에는 디자인의 신규성을 부정하는 것이 신규성의 근본 개념에 부합하는 것이며, 이에 따라 특정 공지디자인에 대해서 신규성 상실의 예외가 인정된다는 것은 더 이상 공지의 영역인 불특정 다수인이 실시할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다는 의미로 이해할 수 있는 것이다.[179]

나 개선점

(1) 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건 완화에 따른 관계의 재정립

디자인 창작자는 자신의 공지디자인에 대하여 신규성 상실의 예외에 근거하여

176) 정태호, 앞의 글(주 48), 682면.

177) 박준석, "특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석", 『민사판례연구』, no.34(2012), 1025 면.

178) 정태호, 앞의 글(주 48), 683면.

179) 정태호, 앞의 글(주 5), 127면.

자신의 창작디자인의 그 형태적인 면에서 디자인권이라는 독점권을 누릴 수 있도록 법적인 효력이 사실상 부여되었다 볼 수 있다.[180] 국제적으로 주요 국가들은 신규성 상실의 예외를 법 규정으로 도입하여 적극적으로 활용하고 있는데, 이와 같은 국제적으로 입법화된 제도를 소수의 국가들에서 고려되고 있는 자유실시디자인과 같은 침해부정에 관한 이론으로 무력화시키는 것은 신규성 상실의 예외 제도에 대한 국제적인 입법동향에도 거스르는 것이다.[181]

대상판결에서는 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판단하였는데, 그 이유로서 '제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실의 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다.'고 판시하였다. 다만, 대상판결 이후 최근 디자인보호법 개정에 의해 형식적인 절차적 요건이 삭제되었다는 점에서, 제3자와의 이익 균형이 약화된 점은 부인할 수 없을 것이다. 다만, 신규성 상실의 예외 적용을 위한 절차와 같은 형식적 요건이 완화되었다 하더라도, 자기 공지 이후에 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 유지되고 있고 본래 보호되어야 할 디자인 등이 보호되는 것일 뿐이다. 또한, 제3자에게는 대상 디자인 등에 관해 신규성 상실 사유를 발견한 경우에, 정보 제공 등에 의해 그 사실을 특허청에 제시할 수 있는 길이 열려 있기 때문에, 디자인보호법의 목적 및 신규성 상실의 예외 규정의 도입 취지 등을 고려하면 제3자의 불이익은 한정적이라 할 것이다.

그러나, 대상판결이 "신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것"이라고 판시하면서, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 한 점을 고려해 볼 때, 자유실시디자인 항변을 주장하기 이전에 그 근거가 되는 공지디자인의 범위를 제한할 수 있는 것이 바로 신규성 상실 예외 규정임을 밝힌 것으로 이해할 수 있다. 즉, 출원디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외 주장이 가능한 공지디자인의 범위가, 자유실시디자인의 항변에서 근거가 되는 공지디자인의 범위에도 영향을 미치는 것이다. 따

180) 정태호, 앞의 글(주 5), 128면.
181) 정태호, 앞의 글(주 5), 129면.

라서 신규성 상실의 예외 규정에서 제3자의 창작적 요소가 부가된 공지디자인과의 관계 등 공지디자인의 범위와 관련한 실체적 요건을 명확하게 규정하여, 디자인 출원인의 이익과 공지디자인을 활용하려고 하는 제3자의 이익 간의 형평을 명확하게 할 필요가 있을 것이다.

(2) 공지디자인 예외 규정으로의 법 개정

신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계가 명확하게 다가오지 않는 이유는, 우선 자유실시디자인의 항변의 규정이 디자인보호법에 규정되어 있지 않기 때문이기도 하다. 중국에서와 같이 자유실시디자인의 항변을 디자인보호법 상에 명문의 규정을 둠으로써, 해당 제도의 존재와 향후 운용의 근거를 마련하는 것이 바람직해 보인다. 다만, 우리나라의 디자인보호법에는 일본에서 이미 도입된 무효의 항변조차도 입법이 되지 않은 상태이므로, 자유실시디자인의 항변은 무효의 항변과 동시에 법규정을 마련하는 것이 바람직해 보인다.

다음으로, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계를 명확하게 하기 위해서는, 현행 신규성 상실의 예외 규정의 제목을 현행의 '신규성의 상실의 예외' 보다는 '공지디자인의 예외'라고 표현하여 선행디자인으로서의 지위가 있는지 여부를 쉽게 알 수 있도록 구체화하는 것이 바람직하다. 가령, 미국 특허법 제102조에서 (a)가 일반적인 선행기술을 규정하고, (b)가 그 선행기술의 예외를 규정하고 있는 것과 같은 개념으로 그 요건을 명확히 할 필요가 있을 것이다. 공지된 디자인의 예외로 개정함으로써, 일정한 예외 사유에 해당하는 경우에 아예 공지되지 않은 것으로 취급한다는 점을 명확히 하여, 공지는 되었으나 일정 요건 하에서만 신규성 상실의 예외를 인정하는 방식을 취하고 있는 현행의 신규성 상실의 예외 규정과는 다른 것으로 운용하게 되는 것이다. 자유실시디자인의 항변은 공지디자인을 기초로 피고실시 디자인이 유사한지 또는 용이하게 창작할 수 있는 것인지를 판단하는 것인바, 그 판단의 기초가 되는 공지디자인에 해당하는지 여부에 대한 판단이 우선되어야 하는데, 만약 어떤 출원인의 디자인이 그 디자인 출원 전 12개월 이내에 공지된 사실이 있다 하더라도, '공지디자인의 예외'에 해당하는지 여부를 명확히 알 수 있도록 한다면, 자유실시디자인의 항변의 인정 여부에 대한 예측 가능성도 높아질 수 있을 것이다.

7 결론

신규성 상실의 예외 규정은, 2023. 6. 20. 법률 제19494호로 일부 개정에 의해 특허청에 대한 서류제출에 관한 절차적 규정이 삭제되었는바, 대상판결에서 근거로 제시하고 있는 제3자의 이익균형이 유지되고 있는 것인지에 대한 재평가가 필요한 시점이다. 다만, 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건과 관련하여서는, 증명서류 등의 제출 절차와 같은 형식적 요건이 완화되었다고 하더라도, 자기 공지 이후에 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 유지되고 있고 본래 보호되어야 할 디자인 등이 보호되는 것이고, 또한, 제3자에게는 대상 디자인 등에 관한 신규성 상실의 사유를 발견한 경우에, 정보 제공 등에 의해 그 사실을 특허청에 제시할 수 있는 길이 열려 있기 때문에, 제3자의 불이익은 한정적이라 볼 수 있다. 아울러, 미국이나 유럽과 같이 12개월 이내 출원해야 하는 요건 이외에는 신규성상실예외 적용을 위한 특별한 절차를 요구하지 않는 국가도 존재하고, 특허와는 다르게 디자인의 경우 공개된 디자인이 축적됨으로써 디자인 산업이 발전하는 것이 아니고, 비밀디자인제도나 관련디자인제도 등을 통해 제3자와의 균형보다는 창작자 보호에 좀 더 비중을 두어왔다는 점에서도, 특허법과 비교하여 상대적으로 예외를 널리 인정할 수 있을 수 있기 때문에, 디자인보호법 상 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건의 완화는 바람직한 방향이라고 볼 수 있다.

신규성 상실의 예외와 관련한 취지나 증명서류 제출 요건의 폐기로 인해, 공지 후 12개월 이내에 출원해야 하는 요건만 충족한다면 절차적 요건은 사실상 문제가 되지 않는바, 향후에는 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건에 관한 운용이 더 중요해질 것으로 보인다. 우리나라 디자인보호법에는 출원인의 출원 전 공개디자인을 모방한 제3자의 공개에 관하여 아무런 규정이 없는바, 미국 디자인 특허나 유럽공동체 디자인 규정과 같이, 제3자가 모방하여 공지한 경우 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 다만, 제3자가 창작자의 공지디자인에 근거했더라도 그것과는 유사하지 않은 것을 창작하여 공지한 경우에는, 제3자와의 형평을 고려하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 제한하는 것이 바람직한 것으로 이해되는바, 이러한 부분에 대한 예측 가능성을 높이기 위해서도 제3

자에 의한 공지에 관한 명확한 규정을 마련하는 것이 바람직해 보인다. 또한, 주요국에서와 같이, 신규성 상실의 예외 규정이 적용될 수 있는 공지디자인의 범위를 출원디자인과의 관계에서 유사범위까지로 제한하는 것이 바람직해 보인다.

관련디자인 제도와 관련하여 디자인보호법상 출원 또는 등록된 기본디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외가 규정되어 있을 뿐, 그 외에 공지된 자기 디자인과의 관계에 대해서는 아무런 규정이 없다. 물론, 관련디자인 출원 전 1년 이내에 공지된 자기 디자인의 경우에는 디자인보호법 제36조에서 규정하는 신규성 상실의 예외를 적용할 수 있게 되지만, 관련디자인으로 등록 가능한 기간이 3년으로 연장된 현재로서는 공지일로부터 1년이 경과된 공지디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외를 적용할 수 없게 된다. 이러한 부분들에 대한 구제가 이루어지지 않게 되면, 최근 디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외 규정에서 기본적인 절차적 요건을 폐지하고 널리 예외를 인정하자는 취지와도 상충될 것이다. 또한, 일본의 경우 관련의장으로 등록 가능한 기간이 10년으로 연장되었음에도 불구하고, 이러한 관련의장에 대해서도 의장법 제10조 제2항 및 제8항에 신규성 상실의 예외 규정을 마련하고 있는 점도 참고할 필요가 있다. 따라서 관련디자인 규정에 신규성 상실의 예외 규정을 추가함으로써 관련디자인과 신규성 상실의 예외 규정의 관계를 명확히 하고, 자기의 디자인과의 관계에서는 그 디자인이 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 선행디자인을 근거로 거절되지 않음을 이해하기 쉽도록 하는 것이 바람직해 보인다.

우리나라의 경우 자유실시디자인의 항변은 등록디자인과 대비되는 디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지는 경우(신규성이 없는 경우)만이 아니라, 이러한 공지디자인 또는 공지디자인들의 결합에 의해 쉽게 실시할 수 있는 경우(창작비용이성이 인정되지 않는 경우)까지도 인정되어, 공지디자인과 동일한 경우에만 인정되는 중국이나 유사한 범위까지만 인정되는 일본보다 그 인정범위가 상대적으로 넓다. 따라서, 우리나라도 장기적으로는 자유실시디자인을 동일 범위(또는 동일·유사 범위)까지만 한정하고, 용이창작 범위에 대해서는 허용하지 않는 방향으로 실무를 변경할 필요가 있다고 생각된다. 다만, 현실적으로는 용이창작 범위까지 허용하는 자유실시디자인의 항변의 법리가 굳건히 활용되고 있는

바, 당장은 그 적용을 제한하는 방향으로 제도를 검토할 필요가 있다.

권리범위확인심판이나 침해소송 등에서 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를 판단하는 자유실시디자인 항변의 판단에서 '디자인의 유사여부'의 판단기준은, 공지디자인의 항변이나 권리남용 항변에서의 등록디자인의 무효여부에 대한 판단, 확인대상디자인(실시제품)이 등록디자인의 권리범위에 속하는지에 대한 판단에서의 '디자인의 유사여부'의 판단기준과 정합성을 가져야 할 것이다. 우리나라에서는, 디자인의 유사여부 판단에서 공지부분을 포함하는 경우, 등록요건을 판단하는 단계와 침해여부를 판단하는 단계에서 그 기준이 달리 적용되고 있으나, 미국 및 일본 등의 주요국에서는 기본적으로 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 동일한 판단 방법이 적용된다는 점에서, 우리나라도 주요국과 같이 판단기준을 통일할 필요가 있는 것으로 생각된다.

한편, 대상판결이 "신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것"이라고 판시하면서, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 하였는바, 이는 자유실시디자인 항변을 주장하기 이전에 그 근거가 되는 공지디자인의 범위를 제한할 수 있는 것이 바로 신규성 상실의 예외 규정임을 밝힌 것이라고 볼 수 있다. 즉, 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건에서 출원디자인과의 관계에서 공지디자인의 범위나 제3자에 의해 공지된 디자인의 범위가, 자유실시디자인 항변에서 근거가 되는 공지디자인의 범위와 연결되는 것이다. 따라서, 디자인 출원인의 이익과 공지디자인을 활용하려고 하는 제3자의 이익 간의 형평을 고려하여, 신규성 상실의 예외 규정에서 공지디자인의 범위 등 실체적 요건을 규정하여, 그 경계를 명확하게 할 필요가 있을 것이다.

한편, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계가 명확하게 이해되지 않는 이유는, 우선 자유실시디자인의 항변의 규정이 디자인보호법에 규정되어 있지 않기 때문이기도 하다. 중국에서와 같이 자유실시디자인의 항변을 디자인보호법 상에 명문의 규정을 둠으로써, 해당 제도의 존재와 향후 운용의 근거를 마련하는 것이 바람직해 보인다. 다만, 우리나라는 일본에서 이미 도입된 무효의

항변조차도 입법이 되지 않은 상태이므로, 자유실시디자인의 항변은 무효의 항변과 동시에 법규정을 마련하는 것이 바람직해 보인다. 다음으로, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계를 명확하게 하기 위해서는, 현행 신규성 상실의 예외 규정의 제목을 '신규성의 상실의 예외' 보다는 '공지디자인의 예외'라고 표현하여, 디자인보호법 제36조에 해당하는 경우에는, 제33조제1항제1호 또는 제2호에서 규정한 공지디자인의 예외가 됨을 명확히 하는 것이 바람직하다.

참 고 문 헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

정상조·박성수,『특허법 주해 Ⅰ』, 박영사, 2010.

노태정·김병진,『디자인보호법』, 세창출판사, 2022.

공경식·이승훈,『코어디자인보호법(제12판)』, 한빛지적소유권센터, 2015.

정상조 외 3인 공편,『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015.

윤태식,『디자인보호법 – 디자인 소송 실무와 이론 -』, 진원사, 2016.

峯 唯夫,『33のテーマで読み解く意匠法』, 勁草書房, 2023.

加藤 幹,『パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論』, 知的財産法学の新たな地平. 2022.

特許庁政策推進懇談会, “知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～”, 特許庁, 2022.

特許庁 総務部 総務課 制度審議室 編集,『逐条解説〔第22版〕意匠法』, 一般社団法人発明推進協会, 2022.

小谷悦司 외 2인 編集,『意匠·デザインの法律相談I (第35巻)(最新青林法律相談 35)』, 青林書院, 2021.

牧野利秋 編,『最新知的財産訴訟実務 含·知財高裁歴代所長座談会』, 青林書院, 2020.

末吉 亙,『新版 意匠法〈第3版〉【知的財産法実務シリーズ】』, 中央経済社, 2017.

中山信弘 編,『新·注解 特許法〔第2版〕』, 弘文堂, 2017.

吉田親司,『意匠の理論(現代産業選書—知的財産実務シリーズ)』, 経済産業調査会, 2017.

中山信弘·小泉直樹 · 編集、『新·注解 特許法』、青林書院、2017.

田村善之,『知的財産法〔第5版〕』, 有斐閣 , 2010.

松本重敏、『特許発明の保護範囲 新版: その理論と実際』、有斐閣, 2000.

三枝英二先生 · 小谷悦司先生還暦記念論文集(著),『判例意匠法—三枝英二先生 · 小谷悦司先生還暦記念』, 発明推進協会, 1999.

斎藤瞭二, 『意匠法』, 発明協会, 1985,

高田 · 忠, 『意匠』, 有斐閣, 1982.

〈학술지(국내 및 동양)〉

권상한, “자유실시디자인 해당 여부 판단시 선행디자인의 표현 정도 [특허법원 2021. 8. 20. 선고 2021허2281 판결]”, 『Law&Technology』, 제18권 제1호(2022).

김기수, “자유실시디자인 판단 시 신규성 상실의 예외 규정 적용 가능성”, 『Law&Technology』, 제16권 제3호(2020).

박선하·양인수, “디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고 —한국과 일본의 비교를 중심으로—“, 지식재산연구, 제17권 제1호(2022).

박정희, “권리범위확인심판에서 특허권 소진을 주장할 수 있는지 여부”, 『특허판례연구』, 3판(2017).

박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 『민사판례연구』, no.34(2012).

신기현, “공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌 —서울중앙지방법원 2018.12.13. 선고 2016가합502475 판결을 중심으로—”, 『지식재산연구』, 제14권 제4호(2019).

신상민, “디자인보호법상 자기공지에 의한 신규성 상실의 예외의 법적 쟁점”, 『법

학연구』, 제20집 제3호(2017).

안원모 “디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도에 관한 고찰, 『산업재산권』, 제71호(2022).

안원모, “미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제11권 제2호(2016).

윤기승, “특허법상 공지예외적용에 관한 연구”, 『국제법무』, vol.11, no.1(2019).

윤선희·이승훈, “자유실시디자인의 항변의 판단 시 고려할 사항 - 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결-”, 『법조』, 제66권 제2호(2017).

정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 『성균관법학』, 27권 3호(2015).

정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 「정보법학」 제17권 제2호(2013).

정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 『사법』, 제1권 제60호(2022).

정태호, “디자인보호법상 창작자 보호 관점에서의 신규성 상실의 예외에 관한 고찰”, 『산업재산권』, 제71호(2022).

정태호, “자유실시디자인과의 관계에 따른 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 개정 규정 관련 입법론의 비판적 검토- 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결 및 2022후10012 판결의 분석을 중심으로 -”, 『정보법학』, 제28권 제1호(2024).

홍정표, “공지예외 제도의 문제점 및 개선방안”, 『지식재산연구』, 9권 4호(2014).

佐々木眞人, “新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和の必要性及び今後の期待”, 『パテント』, Vol. 76 No. 5(2023).

鈴木康平, “意匠法における新規性喪失の例外規定の検討”, 『日本知財学会誌』, Vol.

19 No. 1(2022).

加藤 幹, “意匠の類否判断における公知意匠の参酌”, 『パテント』, Vol. 74, No. 8(2021).

青木大也, “意匠法改正をめぐる諸問題(1)”, 『知的財産法政策学研究』, Vol. 55(2020).

末宗達行, “アメリカにおけるデザインの保護”, デザイン学研究特殊号, Vol.25-2, No.98(2017).

小池 豊, “特許法104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見”, 『パテント』, Vol. 63, No. 8(2010).

牧野知彦, “侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁”, 『知財管理』, 58巻4号(2008).

小橋 馨, “特許法104条の3と公知技術の抗弁”, 『近畿大学法科大学院論集』, 4号(2008).

古城春実, “特許侵害訴訟と公知技術”, 『日本工業所有権法学会』, 年報29号(2006).

三村量一, “他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合”, 『最高裁判所判例解説民事編』平成10年度 (上)(2001).

茶園成樹, “意匠法4条2項における公開された意匠と出願意匠との同一性”, 『特許研究』, 24(1997).

大瀬戸豪志, “特許侵害訴訟における自由技術の抗弁”, 『パテント』, 46巻7号(1993).

〈학술지(서양)〉

Sarah Burstein, “IS DESIGN PATENT EXAMINATION TOO LAX?”, 『BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 』, Vol. 33(2018).

〈기타 자료(국내 및 동양)〉

특허청 편, “디자인보호법 심사기준”, 특허청, 2023.

産業構造審議会知的財産分科会, 意匠の新規性喪失の例外適用手続について, 第13回意匠制度小委員会, 2022.

통상산업위원회전문위원, “의장법중개정법률안 검토보고서”, 통상산업위원회, 1997.

北京魏啓学法律事務所, “意匠権侵害訴訟における公知意匠の抗弁”,

https://www.raytec.co.jp/application/files/9915/4139/2531/201105-IPSP8.pdf, 최종 검색일 2024. 9. 6.

田中汞介, “自由技術の抗弁の現代的意義”, 2021. 12. 21. https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312, 최종 검색일: 2024. 9. 6.

意匠法4条2項の新規性喪失の例外と公開意匠の証明書記載の意匠と引用意匠の同一性に関する「バッグ」事件知財高裁判決について, innoventier power for the Business, 2024, https://innoventier.com/archives/2024/01/16292 , 최종 검색일: 2024. 09. 20.